

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

FACULTAD DE DERECHO

CARRERA DE ABOGACÍA

Derecho Constitucional Profundizado

Guía integral de respuestas para el
Primer Parcial — Comisión 603

28 de septiembre de 2026

Interpretación constitucional y precedente judicial
Control de constitucionalidad, difuso y contramayoritario
El recurso extraordinario federal: requisitos, queja, cautelar y *per saltum*
El principio de reserva, la objeción de conciencia, la libertad religiosa
y la libertad de expresión

*“Comprender es el primer paso para convertir
el estudio en conocimiento.”*

Docentes: Dr. Andrés Uslenghi (Adjunto) — Dr. Darío M. Luna (JTP)

Apunte elaborado por: **Isaac Edgar Camacho Ocampo**

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Constitucional Profundizado”. Reorganiza y desarrolla, en función de la guía de preguntas del primer parcial, los apuntes integrados de la materia, contrastados con el cronograma de la cátedra y completados —donde hacía falta— con fuentes académicas y jurisprudenciales verificables. No pretende sustituir el material oficial de la cátedra ni la lectura de los fallos y normas en su fuente original.

2026

Índice general

Presentación	5
Mapa de la guía	5
 I Interpretación constitucional y precedente judicial	 7
1. Textualismo y no textualismo. <i>Holding</i> y <i>obiter dictum</i> en el precedente judicial	8
1.1. Por qué interpretar la Constitución es un problema	8
1.2. Tres corrientes, ordenadas según su apego a la letra	8
1.2.1. El textualismo	9
1.2.2. El originalismo	9
1.2.3. El pragmatismo o interpretación dinámica	10
1.2.4. Textualismo frente a no textualismo	10
1.3. <i>Holding</i> y <i>obiter dictum</i> en el precedente judicial	11
1.4. Cuadro Cornell: interpretación y precedente	13
 II Control de constitucionalidad	 14
2. Concepto y alcance del control de constitucionalidad. El papel de los tribunales y de la Corte Suprema. La supremacía de la Constitución Nacional	15
2.1. El punto de partida: la supremacía constitucional	15
2.2. El alcance del control: qué puede controlarse y quién lo hace	16
2.3. El papel de los tribunales inferiores y el rol final de la Corte Suprema	16
2.4. Los fallos fundacionales: Marbury v. Madison y Sojo	16
2.4.1. Marbury v. Madison (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1803)	17
2.4.2. Sojo c/ Poder Ejecutivo Nacional (CSJN, 1887)	17

2.5. Cuadro Cornell: concepto, alcance y supremacía	18
3. Control difuso y concentrado de constitucionalidad. Diferencias, ventajas y desventajas; contexto jurídico institucional de cada sistema	20
3.1. El sistema difuso	20
3.2. El sistema concentrado	20
3.3. Comparación: diferencias, ventajas y desventajas	21
3.3.1. Ventajas del sistema difuso	21
3.3.2. Costos y desventajas del sistema difuso	21
3.3.3. Contexto jurídico-institucional de cada sistema	22
3.4. Cuadro Cornell: control difuso y concentrado	22
4. El Poder Judicial como poder contramayoritario	23
4.1. El problema: jueces no electos que invalidan leyes de representantes electos	23
4.2. La respuesta de Ely: la teoría del refuerzo de representación	24
4.2.1. La nota al pie n.º 4 de <i>Carolene Products</i>	24
4.3. El poder judicial y los procesos políticos: <i>Baker v. Carr</i>	25
4.4. Síntesis: cómo se articula la objeción contramayoritaria con su respuesta .	26
4.5. Cuadro Cornell: el Poder Judicial contramayoritario	26
III El recurso extraordinario federal	28
5. Cuestión federal simple o compleja (directa e indirecta)	29
5.1. Ubicación del tema: el corazón del recurso extraordinario	29
5.2. Cuestión federal simple	29
5.3. Cuestión federal compleja: directa e indirecta	30
5.4. Elementos adicionales: decisión contraria y relación directa e inmediata .	30
5.5. Cuadro Cornell: cuestión federal	31
6. Arbitrariedad de sentencia. Supuestos y alcance de la revisión	32
6.1. Una vía de revisión más allá de la cuestión federal	32
6.2. Supuestos de arbitrariedad	33
6.2.1. Errores en la valoración de la prueba	33
6.2.2. Errores en el encuadramiento jurídico	33
6.2.3. Violación del principio de congruencia	33
6.2.4. Exceso del tribunal de Cámara respecto de los agravios	33

6.3. Alcance de la revisión: honorarios, intereses y coexistencia con la cuestión federal	34
6.4. Cuadro Cornell: arbitrariedad de sentencia	34
7. Control de constitucionalidad de oficio. Fundamentos y precedentes	35
7.1. Concepto y fundamento	35
7.2. El límite: la congruencia con la pretensión de la parte	35
7.3. Precedentes históricos	36
7.4. Vínculo con el recurso extraordinario federal	36
7.5. Cuadro Cornell: inconstitucionalidad de oficio	36
8. Recurso extraordinario: requisitos formales, comunes y propios	38
8.1. El recurso extraordinario como mecanismo de impugnación	38
8.1.1. Requisitos formales	38
8.1.2. Requisitos comunes a todo recurso judicial	39
8.1.3. Requisitos propios: sentencia definitiva o asimilable	39
8.2. Cuadro Cornell: requisitos del recurso extraordinario	40
9. Recurso de queja	41
9.1. Cuándo procede	41
9.2. Objeto de la queja y efectos	41
9.3. Cuadro Cornell: recurso de queja	42
10. Medida cautelar. Presupuestos. Su relación con el recurso extraordinario	43
10.1. Concepto y función	43
10.2. Los tres presupuestos clásicos	43
10.3. Relación con el recurso extraordinario	44
10.4. Cuadro Cornell: medida cautelar	44
11. <i>Per saltum</i>	46
11.1. Concepto y marco normativo	46
11.2. Requisitos	46
11.3. Cuadro Cornell: <i>per saltum</i>	47

IV El principio de reserva y los derechos individuales	48
12.Principio de reserva. Objeción de conciencia	49
12.1. El artículo 19: el principio de reserva	49
12.2. La objeción de conciencia	50
12.2.1. El caso “Portillo” (CSJN, 1989)	50
12.2.2. El caso “Bahamondez” (CSJN, 1993)	51
12.3. Cuadro Cornell: principio de reserva y objeción de conciencia	52
13.Libertad religiosa	54
13.1. La Iglesia como persona jurídica de derecho público	54
13.2. Categorías sospechosas	54
13.3. El caso de la educación religiosa obligatoria en Salta	55
13.4. Otros ámbitos de aplicación	55
13.4.1. Testigos de Jehová y transfusiones de sangre	55
13.4.2. Educación en el hogar y comunidades menonitas	56
13.4.3. Objeción religiosa al servicio militar	56
13.5. Cuadro Cornell: libertad religiosa	56
14.Libertad de expresión. Prohibición de censura previa. Doctrina Campillay y doctrina de la real malicia. Derecho de réplica	58
14.1. La doble dimensión de la libertad de expresión y su importancia democrática	58
14.2. La prohibición de censura previa	59
14.3. La doctrina de la real malicia	59
14.4. La doctrina Campillay	60
14.5. El derecho de réplica: el caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”	61
14.5.1. Los hechos del caso	61
14.5.2. La decisión de la Corte Suprema	61
14.6. Relación entre las cuatro doctrinas de este capítulo	62
14.7. Cuadro Cornell: libertad de expresión	63
Síntesis final	65
Bibliografía y fuentes	67
Material proporcionado por la cátedra	67
Fuentes externas consultadas	67

Presentación

Este volumen no es un apunte general de la materia, sino un desarrollo dirigido, punto por punto, a la **guía de preguntas del primer parcial** de Derecho Constitucional Profundizado (Comisión 603), a rendirse el 28 de septiembre de 2026. Toma como fuente principal los apuntes integrados de la cátedra —que cubren con solvencia la mayor parte de los catorce puntos de la guía— y los reorganiza en el orden exacto en que la guía los presenta, profundizando cada concepto desde su base, para que cada respuesta pueda estudiarse de manera autónoma.

En cuatro puntos de la guía los apuntes originales no traían desarrollo propio —la distinción entre *holding* y *obiter dictum*, el carácter contramayoritario del Poder Judicial, la objeción de conciencia (con los casos “Portillo” y “Bahamondez”) y el derecho de réplica (caso “Ekmekdjian c/ Sofovich”)—. Para esos puntos se investigó en fuentes académicas y jurisprudenciales confiables, que se citan en la bibliografía final, y se indica expresamente que se trata de una ampliación externa y no de contenido tomado de los apuntes de clase.

Este material combina tres fuentes: (1) los apuntes integrados de la cátedra, que constituyen la base y la orientación de cada respuesta; (2) el cronograma de clases de la Comisión 603, utilizado para verificar qué bibliografía y qué fallos corresponden a cada tema; y (3) fuentes académicas externas, utilizadas únicamente para completar los puntos de la guía que los apuntes no desarrollaban todavía. Cuando se recurrió a una fuente externa, se lo indica expresamente en el cuerpo del texto. No se ha inventado ningún autor, cita, fallo ni referencia normativa: donde no fue posible verificar un dato con las fuentes disponibles, se señala expresamente esa limitación en lugar de presentarlo como un hecho. Este apunte no reemplaza la lectura de los fallos, normas y manuales de la bibliografía oficial de la cátedra.

Mapa de la guía

La guía de catorce puntos se agrupa aquí en cuatro partes, que siguen la misma progresión lógica que el programa de la materia:

- **Parte I — Interpretación y precedente.** Textualismo y no textualismo; *holding* y *obiter dictum* (Pregunta 1).

- **Parte II — Control de constitucionalidad.** Concepto y alcance; supremacía constitucional (Pregunta 2); control difuso y concentrado (Pregunta 3); el Poder Judicial como poder contramayoritario (Pregunta 4).
- **Parte III — El recurso extraordinario federal.** Cuestión federal simple y compleja (Pregunta 5); arbitrariedad de sentencia (Pregunta 6); control de oficio (Pregunta 7); requisitos del recurso extraordinario (Pregunta 8); recurso de queja (Pregunta 9); medida cautelar (Pregunta 10); *per saltum* (Pregunta 11).
- **Parte IV — El principio de reserva y los derechos individuales.** Principio de reserva y objeción de conciencia (Pregunta 12); libertad religiosa (Pregunta 13); libertad de expresión, censura previa, doctrina Campillay, real malicia y derecho de réplica (Pregunta 14).

Dentro de cada parte, cada pregunta se desarrolla siguiendo, en la medida en que resulte útil, la progresión: contexto → concepto → fundamento → desarrollo → relación con otros temas → jurisprudencia y ejemplos → respuesta para el examen. Al cierre de cada parte se incluye un cuadro Cornell de repaso.

Parte I

Interpretación constitucional y precedente judicial

Pregunta 1

Textualismo y no textualismo. *Holding* y *obiter dictum* en el precedente judicial

1.1. Por qué interpretar la Constitución es un problema

Toda norma necesita ser interpretada antes de ser aplicada, pero la Constitución plantea un problema adicional: es un texto fundacional que, a diferencia de una ley ordinaria, no se actualiza automáticamente con el paso del tiempo. Una ley puede reformarse con relativa facilidad cuando deja de responder a las necesidades sociales; la Constitución, en cambio, está pensada para perdurar, y solo puede modificarse mediante un procedimiento de reforma agravado. El resultado es una tensión permanente entre un texto que se mantiene estable y una realidad social, tecnológica y económica que cambia constantemente. Basta pensar que hace apenas diez años la inteligencia artificial se percibía como ciencia ficción, y hoy plantea problemas interpretativos concretos que ningún constituyente pudo prever.

Frente a ese problema, la primera fuente de interpretación constitucional es siempre la letra de la norma. Pero cuando la letra por sí sola no permite resolver el caso —porque es ambigua, porque colisiona con otra norma, o porque describe una situación que el constituyente no imaginó— es necesario recurrir a un método, a una *corriente de interpretación*, que oriente al intérprete sobre qué peso darle al texto, a la intención histórica de quien lo redactó, o a los fines que persigue.

1.2. Tres corrientes, ordenadas según su apego a la letra

La cátedra distingue tres grandes corrientes de interpretación constitucional, ordenadas de mayor a menor apego literal al texto: el **textualismo**, el **originalismo** y el **pragmatismo** (o interpretación dinámica). La guía de examen agrupa estas corrientes bajo la dicotomía clásica **textualismo y no textualismo**: el textualismo por un lado, y por

el otro —como variantes de una misma actitud de apartarse de la literalidad estricta— el originalismo y el pragmatismo, cada uno por una vía distinta.

1.2.1. El textualismo

Corriente que afianza el valor de la letra como primera fuente de interpretación y le da un sentido estricto: la letra no es solo la primera referencia a la hora de interpretar la norma, sino que además reduce fuertemente la creatividad del juez o del órgano que la aplica, porque es el propio texto el que marca los límites de lo interpretable.

En la jurisprudencia argentina, la Corte Suprema sostiene que la primera fuente de interpretación es la letra de la norma, entendida según el uso o significado corriente que las palabras tienen en los tiempos actuales. Se trata de una modulación más flexible que el textualismo puro norteamericano: la Corte argentina no congela el significado de las palabras en el momento histórico de la sanción, sino que las interpreta con el sentido que tienen hoy.

La tenencia de estupefacientes para consumo personal plantea la cuestión de qué extensión darle a las expresiones del artículo 19 de la Constitución Nacional según las cuales las acciones privadas no pueden ofender la moral ni las buenas costumbres, ni perjudicar a terceros (desarrollado en profundidad en el Capítulo 12). Una lectura textualista acota la interpretación a la literalidad de esas palabras; otras corrientes admiten un margen mayor para proyectar la norma a los tiempos actuales.

1.2.2. El originalismo

Corriente según la cual la interpretación debe responder a la fidelidad del texto, pero además debe estar imbuida del período histórico en que la norma fue redactada: las palabras tienen el sentido que tenían históricamente al momento de su sanción, según la voluntad de quienes la dictaron.

El originalismo no es equivalente al textualismo, aunque ambas son corrientes *restrictivas* de la actividad judicial: buscan achicar el margen de creación del juez, pero por vías distintas. El textualismo se apoya en el texto y su significado actual; el originalismo agrega el peso histórico de la voluntad de los constituyentes.

Cuadro 1.1: Textualismo y originalismo: dos variantes conservadoras

Dimensión	Textualismo	Originalismo
Fuente primaria	Letra de la norma	Letra y contexto histórico de sanción
Significado de las palabras	Uso corriente y actual	Sentido al momento de la redacción
Rol del juez	Muy limitado por el texto	Limitado por texto e historia legislativa
Arraigo en Argentina	Moderado (doctrina de la Corte)	Débil
Arraigo en EE. UU.	Fuerte	Muy fuerte (jueces conservadores)

En el derecho argentino el originalismo tiene un arraigo más débil que en Estados Unidos, donde la apelación a la voluntad de los “padres fundadores” es una tradición consolidada. Un condicionante práctico explica en parte esa diferencia: no existe una constancia documentada tan clara de los debates de la Asamblea Constituyente de 1853 (la de 1860 está algo más documentada) como sí existe de la Convención de Filadelfia de 1787.

1.2.3. El pragmatismo o interpretación dinámica

La corriente más flexible de las tres. Prioriza mantener actualizados los principios constitucionales esenciales por sobre la voluntad explícita del legislador originario o la letra estricta, otorgando al intérprete un rol más activo y creativo.

El pragmatismo es la corriente con mayor fertilidad interpretativa, porque no busca su fundamento en el texto ni en la intención histórica, sino en mantener vigentes los principios esenciales de la Constitución, reconociendo que los constituyentes originales —aunque sabios— fueron “producto de un tiempo que ya no existe”.

1.2.4. Textualismo frente a no textualismo

Vista en conjunto, la clasificación de la guía puede reconstruirse así:

Cuadro 1.2: Textualismo y no textualismo

Postura	Corrientes que la integran y su lógica común
Textualismo	El textualismo puro: la letra, en su sentido actual, es la única fuente legítima y el límite del intérprete.
No textualismo	El originalismo (se aparta de la letra actual para atender a la voluntad histórica) y el pragmatismo (se aparta tanto de la letra como de la historia para atender a los fines y principios actuales). Ambas variantes admiten, por caminos distintos, que el intérprete mire más allá del texto puro.

No confundir “no textualista” con “antitextual”. Ni el originalismo ni el pragmatismo prescinden del texto: ambos parten de él, pero admiten —a diferencia del textualismo puro— que otros elementos (la historia, los principios, la finalidad) intervengan legítimamente en la interpretación final.

Como complemento transversal, la cátedra incorpora el **análisis económico del derecho**: la idea de que todo gran diseño institucional tiene efectos económicos concretos, y que cualquier análisis de un fallo o de una decisión judicial debería tenerlos en cuenta, sin que ello convierta a la materia en una disciplina económica.

1.3. *Holding* y *obiter dictum* en el precedente judicial

Los apuntes de la cátedra no traían un desarrollo propio de esta distinción. El contenido que sigue se elaboró consultando doctrina procesal y constitucional argentina especializada en la teoría del precedente (véase la bibliografía al final del volumen).

Cuando un tribunal dicta sentencia, no todas las razones que expone en sus considerandos tienen el mismo valor como precedente para casos futuros. La teoría del precedente distingue entre lo que fue efectivamente decisivo para resolver el caso y lo que el tribunal dijo “de paso”, sin que fuera necesario para llegar a esa decisión.

Es la regla de derecho que resulta estrictamente necesaria para resolver el caso concreto: el razonamiento dirimente sobre cuya base el tribunal llega a la decisión. Es la parte de la sentencia dotada de fuerza de precedente, la que vincula a los tribunales inferiores y orienta la resolución de casos análogos futuros.

Expresión latina que significa literalmente “dicho de paso”. Son los argumentos, reflexiones o afirmaciones que aparecen en la parte considerativa de una sentencia, pero que no resultan imprescindibles para la decisión adoptada: acompañan, corroboran o contextualizan el razonamiento central, sin ser su fundamento dirimente. Por eso no sientan precedente obligatorio en sentido estricto, aunque pueden tener fuerza persuasiva si provienen de un tribunal de gran prestigio o si, por su claridad, son retomados en fallos posteriores.

Cuadro 1.3: *Holding* y *obiter dictum*

Aspecto	<i>Holding</i>	<i>Obiter dictum</i>
Relación con el fallo	Es la razón que decide el caso	Es periférico: acompaña sin decidir
Fuerza como precedente	Vinculante (en el sistema argentino, con matices: la CSJN no está formalmente atada a sus propios precedentes, salvo sentencias plenarias, pero su autoridad institucional genera un fuerte deber moral de seguirlos)	Meramente persuasivo, según el prestigio del tribunal
Reversibilidad	Puede perder su carácter dirimente si otro argumento pasa a sostener la decisión	Puede pasar a ser dirimente si, atacado con éxito el argumento principal, el obiter alcanza por sí solo para sostener la decisión

El ejemplo más célebre de esta distinción en el derecho comparado es la nota al pie n.º 4 del caso *United States v. Carolene Products Co.* (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1938): un párrafo que, técnicamente, era un *obiter dictum* —no era necesario para resolver el caso, referido a la regulación de la leche reconstituida—, pero que terminó siendo la base doctrinal de todo el desarrollo posterior sobre el escrutinio judicial reforzado a favor de las minorías discretas e insulares, como se retoma en el Capítulo 4.

Por qué importa distinguirlos al analizar un fallo. Cuando se estudia un precedente para responder una pregunta de examen, no alcanza con citar “lo que dijo la Corte”: hay que identificar cuál fue el *holding* —la regla que efectivamente decidió el caso y que puede invocarse como precedente— y separar los *obiter dicta*, que sirven para comprender el contexto y el razonamiento del tribunal, pero no pueden invocarse con el mismo peso normativo.

1.4. Cuadro Cornell: interpretación y precedente

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Cuál es el problema central de la interpretación constitucional?	Que un texto fundacional, estable en el tiempo, debe aplicarse a una realidad social que cambia mucho más rápido, sin que medie necesariamente una reforma.
¿Qué es el textualismo?	La corriente que da a la letra, en su sentido actual, el rol de primera y casi excluyente fuente de interpretación, reduciendo al mínimo la creatividad judicial.
¿En qué se diferencia el originalismo del textualismo?	El originalismo agrega el peso de la voluntad histórica de los constituyentes; el textualismo se limita al significado actual de las palabras.
¿Qué caracteriza al pragmatismo?	Prioriza mantener vigentes los principios esenciales de la Constitución por sobre la letra o la historia, con mayor fertilidad para la reinterpretación.
¿Cómo se agrupan estas corrientes en textualismo y no textualismo?	El textualismo por un lado; el originalismo y el pragmatismo, por vías distintas, como variantes del no textualismo, en tanto ambos admiten mirar más allá de la letra pura.
¿Qué es el <i>holding</i> ?	La razón estrictamente necesaria para decidir el caso: la regla que sienta precedente.
¿Qué es el <i>obiter dictum</i> ?	Lo dicho “de paso” en la sentencia, que no fue necesario para la decisión y que solo tiene fuerza persuasiva.
¿Por qué importa la nota al pie n.º 4 de <i>Carolene Products</i> ?	Porque, siendo técnicamente un <i>obiter dictum</i> , se convirtió en el fundamento doctrinal del escrutinio judicial reforzado a favor de minorías discretas e insulares.

Resumen: frente a un texto que envejece, tres corrientes disputan su interpretación —textualismo, originalismo y pragmatismo—, agrupables en la dicotomía textualismo/no textualismo según su apego a la letra. Al analizar cualquier precedente judicial, es indispensable distinguir el *holding* —la razón dirimente, dotada de fuerza de precedente— del *obiter dictum* —lo dicho de paso, con valor meramente persuasivo—, aunque un *obiter* especialmente influyente, como la nota 4 de *Carolene Products*, puede terminar orientando toda una línea jurisprudencial posterior.

Parte II

Control de constitucionalidad

Pregunta 2

Concepto y alcance del control de constitucionalidad. El papel de los tribunales y de la Corte Suprema. La supremacía de la Constitución Nacional

2.1. El punto de partida: la supremacía constitucional

Principio, consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, según el cual la Constitución Nacional, las leyes que en su consecuencia dicte el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales.

La supremacía constitucional implica una jerarquía: ninguna norma inferior —ley, decreto, ordenanza, sentencia— puede contradecir a la Constitución. Pero afirmar esa jerarquía en abstracto no basta: hace falta un mecanismo que, en cada caso concreto, permita verificar si una norma inferior efectivamente la respeta, y que prive de efectos a la que no lo haga. Ese mecanismo es el **control de constitucionalidad**.

Mecanismo institucional por el cual un órgano del Estado —en la Argentina, cualquier juez, con la Corte Suprema como intérprete final— verifica si una norma o un acto de los poderes públicos se ajusta a la Constitución y, en caso de contradicción, declara su invalidez para el caso concreto, privándola de aplicación.

CAPÍTULO 2. CONCEPTO Y ALCANCE DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES Y DE LA CORTE
Derecho Constitucional SUPLENIDA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

2.2. El alcance del control: qué puede controlarse y quién lo hace

En el sistema argentino, cualquier juez llamado a resolver un conflicto puede, siempre que se trate de una cuestión justiciable —es decir, de un caso o controversia concreto, no de una consulta abstracta—, ejercer el control de constitucionalidad y, como *última ratio* del ordenamiento, invalidar una norma emanada del Congreso o del Poder Ejecutivo: una ley, un decreto o un decreto de necesidad y urgencia. Este es el llamado **sistema difuso**, que se desarrolla en detalle en el Capítulo 3.

El control no se limita a las leyes: alcanza también a los decretos, a los actos administrativos y, en general, a cualquier acto de los poderes públicos que pueda colisionar con la Constitución. Lo que lo activa siempre es un caso judicial concreto: sin un conflicto de intereses entre partes que deba resolverse, no hay control de constitucionalidad posible, porque el Poder Judicial argentino no resuelve consultas abstractas sobre la validez de las normas.

2.3. El papel de los tribunales inferiores y el rol final de la Corte Suprema

Si todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una norma, es imprescindible que exista un órgano que ordene y unifique esas decisiones, para evitar el caos de sentencias contradictorias. Ese rol lo cumple la **Corte Suprema de Justicia de la Nación**, como intérprete final y máximo de la Constitución. La Corte no es el único tribunal habilitado para ejercer el control —cualquier juez de primera instancia puede hacerlo—, pero sí es la última instancia a la que, mediante el recurso extraordinario federal (desarrollado en el Capítulo 8), puede llegar cualquier cuestión constitucional, para que fije un criterio uniforme y definitivo.

El sistema difuso necesita un principio ordenador. Sin un órgano que unifique el criterio, el sistema difuso caería en decisiones caóticas y contradictorias. Ese rol ordenador lo cumple la Corte Suprema, no porque monopolice el control, sino porque es el intérprete final ante quien todas las líneas de interpretación terminan convergiendo.

2.4. Los fallos fundacionales: Marbury v. Madison y Sojo

El origen histórico de esta atribución judicial —que ninguna Constitución escrita establece de manera expresa y detallada— se remonta a dos fallos fundacionales, uno norteamericano y uno argentino, que responden a la misma pregunta: quién tiene la última palabra sobre el significado de la Constitución.

CAPÍTULO 2. CONCEPTO Y ALCANCE DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES Y DE LA CORTE
SUPREMA

2.4.1. Marbury v. Madison (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1803)

El trasfondo político del caso fue el siguiente: el presidente saliente John Adams, tras perder la elección frente a Thomas Jefferson, había nombrado a 42 jueces que todavía no habían asumido sus cargos. Jefferson, ya electo, se negó a completar esos nombramientos y sostuvo que él mismo podía interpretar la Constitución sin someterse al criterio de los tribunales. William Marbury, uno de los jueces nombrados, reclamó directamente ante la Corte Suprema que se lo pusiera en funciones.

El presidente de la Corte, John Marshall, resolvió el caso con un razonamiento de tres preguntas:

Cuadro 2.1: La “lógica de Marshall” en *Marbury v. Madison*

N.º	Pregunta	Respuesta
1. ^a	¿Existió el acto de nombramiento?	Sí
2. ^a	¿Tiene Marbury un derecho y acudió al lugar adecuado?	Sí
3. ^a	¿Puede el Poder Judicial ordenar, mediante un <i>mandamus</i> , que se lo ponga en el cargo?	No: invadiría al Ejecutivo

Ante la tercera pregunta la Corte se autorrestringió —declaró inconstitucional la sección de la *Judiciary Act* que le daba competencia originaria para emitir el mandamus— y, paradójicamente, ganó más: quedó consagrada como el único órgano capacitado para interpretar y decir lo que es la ley, incluso frente al Presidente. De allí la frase célebre del fallo: “el gobierno de los Estados Unidos es un gobierno de leyes y no de hombres”.

“No tenemos ni la bolsa ni la espada”. El Poder Judicial no es el más fuerte de los tres poderes, sino el más débil: no controla los fondos públicos (la “bolsa”, en manos del Legislativo) ni el monopolio de la fuerza (la “espada”, en manos del Ejecutivo). Su único recurso es la autoridad de decir lo que la Constitución significa. Esta debilidad institucional es, precisamente, la que alimenta la objeción contramayoritaria que se estudia en el Capítulo 4: un poder sin respaldo electoral directo termina, sin embargo, invalidando las decisiones de los poderes que sí lo tienen.

2.4.2. Sojo c/ Poder Ejecutivo Nacional (CSJN, 1887)

En la Argentina, apenas veinticinco años después de sancionada la Constitución de 1853/60, se presentó un caso análogo. Eduardo Sojo, un dibujante que publicó una caricatura política satírica, fue detenido sin juicio previo por orden del Congreso. Su abogado planteó un habeas corpus directamente ante la Corte Suprema, en lugar de ante un juez de primera instancia.

La Corte interpretó los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional (entonces 100 y 101): el artículo 116 establece la regla general, la competencia por apelación, agotando

CAPÍTULO 2. CONCEPTO Y ALCANCE DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES Y DE LA CORTE SUPREMA

Derecho Constitucional SUPLENIDA La SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL las instancias desde la más baja; el artículo 117 establece la excepción, la competencia originaria y exclusiva de la Corte, reservada —bajo un *numerus clausus* taxativo— a los casos que involucran embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y a las causas en que una provincia sea parte. Como Sojo no encuadraba en ninguno de esos supuestos, la Corte remitió la causa al juez de primera instancia, quien hizo lugar al habeas corpus y liberó a Sojo.

Cuadro 2.2: Marbury y Sojo: comparación

	Marbury v. Madison	Sojo c/ Poder Ejecutivo
Cuestión de fondo	Control de constitucionalidad	Jurisdicción y competencia, no inconstitucionalidad
Vía elegida	Directamente ante la Corte	Directamente ante la Corte
Resultado	La Corte se consolida como intérprete final de la Constitución	La Corte remite el caso a primera instancia; Sojo es liberado allí

Aunque los resultados procesales fueron distintos, el efecto sistémico es el mismo: en ambos casos queda consolidada la idea de que son los tribunales —y en última instancia la Corte Suprema— quienes dicen qué significa la Constitución, y que ese poder de control corresponde, en el sistema argentino, a todos los jueces y no solo al tribunal cimero (control difuso, Capítulo 3).

2.5. Cuadro Cornell: concepto, alcance y supremacía

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la supremacía constitucional?	El principio del artículo 31 CN según el cual la Constitución, las leyes que en su consecuencia se dicten y los tratados son la ley suprema de la Nación, por sobre cualquier norma provincial o inferior.
¿Qué es el control de constitucionalidad?	El mecanismo por el cual un juez, en un caso concreto, verifica si una norma respeta la Constitución y, si no lo hace, la declara inválida para ese caso.
¿Qué hace falta para que proceda el control?	Un caso o controversia judicial concreto y justiciable; no procede como consulta abstracta.
¿Quién ejerce el control en Argentina?	Cualquier juez, en cualquier proceso (sistema difuso), con la Corte Suprema como intérprete final y ordenador del sistema.
¿Qué estableció <i>Marbury v. Madison</i> ?	Que el Poder Judicial es el único órgano capacitado para decir qué significa la Constitución, incluso frente al Presidente, aunque el Poder Judicial “no tiene ni la bolsa ni la espada”.

CAPÍTULO 2. CONCEPTO Y ALCANCE DEL CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD. EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES Y DE LA CORTE
~~Derecho Constitucional y Político~~ SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Preguntas / palabras clave **Notas / respuestas**

¿Qué resolvió *Sojo*?

Que el caso no era de inconstitucionalidad sino de competencia: la vía originaria ante la Corte es excepcional y taxativa (art. 117 CN); la regla es la apelación (art. 116 CN).

Resumen: la supremacía constitucional (art. 31 CN) exige un mecanismo que la haga efectiva en cada caso: el control de constitucionalidad, ejercido en la Argentina por todos los jueces (sistema difuso) y ordenado, en última instancia, por la Corte Suprema. *Marbury* y *Sojo* son los fallos fundacionales que consolidaron esta atribución judicial en Estados Unidos y en la Argentina, respectivamente.

Pregunta 3

Control difuso y concentrado de constitucionalidad. Diferencias, ventajas y desventajas; contexto jurídico institucional de cada sistema

3.1. El sistema difuso

Sistema, adoptado por la Argentina y por los Estados Unidos, en el que todos los jueces —y no solo la Corte Suprema— tienen el poder de declarar inconstitucional una norma en un caso concreto, en la medida en que sea conducente para resolver el conflicto. No existe un tribunal con competencia exclusiva y excluyente para resolver esa cuestión, como sí sucede en otros ordenamientos.

En el sistema argentino, cualquier juez, al resolver un caso, puede invalidar —como *última ratio*— una ley, un decreto o un decreto de necesidad y urgencia que contradiga la Constitución. Ese poder no está concentrado en un tribunal especial: está *difundido* entre toda la magistratura.

3.2. El sistema concentrado

En el sistema continental europeo —por ejemplo, en Italia, Alemania y España— existen **tribunales constitucionales**, que ejercen en forma exclusiva y excluyente el control de constitucionalidad. Un juez ordinario, en esos sistemas, no puede por sí mismo declarar inválida una ley: debe plantear la cuestión ante el tribunal especializado, que es el único habilitado para resolverla, generalmente con efectos generales (*erga omnes*) hacia el futuro.

CAPÍTULO 3. CONTROL DIFUSO Y CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD.
 DIFERENCIAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS; CONTEXTO JURÍDICO
Derecho Constitucional Profundizado INSTITUCIONAL DE CADA SISTEMA

3.3. Comparación: diferencias, ventajas y desventajas

Cuadro 3.1: Sistema difuso y sistema concentrado

Característica	Sistema difuso (Argentina / EE. UU.)	Sistema concentrado (España / Alemania / Italia)
¿Quién ejerce el control?	Cualquier juez, en cualquier proceso	Un tribunal constitucional especializado y exclusivo
Acceso del justiciable	Directo, en el mismo proceso	Indirecto: se remite al tribunal especializado
Alcance de la decisión	Para el caso concreto (<i>inter partes</i>)	Efecto general (<i>erga omnes</i>)
Riesgo principal	Sentencias contradictorias entre juzgados	Menor acceso directo para justiciables sin recursos para litigar hasta esa instancia
Carácter	Más democrático y accesible	Más especializado, más previsible en su efecto general

3.3.1. Ventajas del sistema difuso

El sistema difuso, con sus imperfecciones, resulta más democrático porque está al alcance de todos: cualquier abogado puede plantear la invalidez de una norma en cualquier proceso; el justiciable no debe esperar la intervención de un tribunal lejano y especializado, porque la cuestión se resuelve en el mismo expediente; y el paso por las sucesivas instancias recursivas enriquece el debate y permite una maduración progresiva de los argumentos antes de llegar, eventualmente, a la Corte Suprema.

3.3.2. Costos y desventajas del sistema difuso

Como contrapartida, el sistema difuso genera un plazo de incertidumbre: pueden existir, durante un tiempo, sentencias contrapuestas sobre la misma norma; una ley general puede quedar puesta en duda o inaplicada en algunos casos y no en otros, generando la situación —a veces contraintuitiva pero real— de que la misma norma se aplique para algunos justiciables y no para otros; y pueden generarse tensiones entre los poderes del Estado mientras la cuestión no queda zanjada definitivamente. Estos son los llamados **costos de transacción** del sistema difuso.

El sistema difuso necesita un principio ordenador. Los costos de transacción recién descriptos explican por qué el sistema difuso no podría funcionar sin la Corte Suprema actuando como intérprete final y unificador de criterio, como se explicó en el Capítulo 2: sin ese rol ordenador, el sistema caería en decisiones caóticas y contradictorias.

La diferencia entre ambos sistemas no es casual, sino que responde a tradiciones jurídicas distintas. El sistema difuso nace en el *common law* norteamericano, donde los jueces gozan históricamente de un fuerte poder creador y donde la fuerza del precedente judicial (*stare decisis*) permite, a pesar de la dispersión del control, mantener cierta uniformidad interpretativa a través del tiempo. La Argentina, país de tradición continental en su derecho de fondo pero que copió el modelo de control judicial norteamericano, combina ambos elementos: un Código Civil y Comercial y un Código Penal únicos para todo el país (a diferencia de Estados Unidos, donde cada estado tiene su propia legislación de fondo), con un control de constitucionalidad difuso a la manera estadounidense.

El sistema concentrado, en cambio, nace en la tradición continental europea de posguerra (el modelo austríaco de Hans Kelsen, adoptado luego por Alemania, Italia y España), en sistemas donde el Poder Judicial ordinario, por tradición, tenía un rol más restringido frente a la ley del Parlamento, y donde se prefirió crear un órgano especial, con una legitimidad y una composición particulares (a menudo con participación de otros poderes en la designación de sus miembros), para concentrar la tarea, sensible desde el punto de vista institucional, de invalidar leyes con efectos generales.

3.4. Cuadro Cornell: control difuso y concentrado

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el sistema difuso?	Aquel en que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma en el caso concreto que está resolviendo.
¿Qué es el sistema concentrado?	Aquel en que solo un tribunal constitucional especializado y exclusivo puede declarar la inconstitucionalidad, generalmente con efectos <i>erga omnes</i> .
¿Cuál es la principal ventaja del sistema difuso?	Su accesibilidad democrática: cualquier justiciable puede plantear la cuestión en el mismo proceso, sin esperar a un tribunal especial.
¿Cuál es su principal costo?	La posibilidad de sentencias contradictorias y de un período de incertidumbre mientras la cuestión no llega a la Corte Suprema.
¿De qué tradición proviene cada sistema?	El difuso, del <i>common law</i> norteamericano; el concentrado, de la tradición continental europea de posguerra (modelo kelseniano).
Resumen: el sistema difuso argentino —cualquier juez, efecto <i>inter partes</i> — es más accesible y democrático, pero exige un principio ordenador (la Corte Suprema) para evitar sentencias contradictorias; el sistema concentrado europeo —un tribunal constitucional exclusivo, efecto <i>erga omnes</i> — gana en uniformidad y previsibilidad, pero resulta menos accesible en forma directa para el justiciable común.	

Pregunta 4

El Poder Judicial como poder contramayoritario

Los apuntes de la cátedra no traían un desarrollo propio de este punto, aunque el cronograma de la Comisión 603 lo incluye expresamente (clase del 31/08, con bibliografía de Ely y el fallo *United States v. Carolene Products Co.*). El desarrollo que sigue se elaboró consultando doctrina constitucional especializada en la llamada “dificultad contramayoritaria” (véase la bibliografía final).

4.1. El problema: jueces no electos que invalidan leyes de representantes electos

Como se vio en el Capítulo 2, a partir de *Marbury v. Madison* y de *Sojo* quedó consolidada la atribución de los jueces de declarar inválida una ley del Congreso o un acto del Poder Ejecutivo que contradiga la Constitución. Pero esa atribución plantea una tensión que la teoría democrática no puede ignorar: los jueces no son elegidos por el voto popular —o lo son solo de manera muy mediata, a través de mecanismos de designación en los que interviene el Poder Ejecutivo y el Senado—, y sin embargo tienen la última palabra para dejar sin efecto una ley sancionada por los representantes que sí fueron elegidos directamente por el pueblo.

Expresión acuñada por el jurista norteamericano Alexander Bickel en su obra *The Least Dangerous Branch* (1962) para describir la tensión estructural entre el control judicial de constitucionalidad y el principio democrático: cuando la Corte Suprema declara inconstitucional un acto legislativo, frustra la voluntad de los representantes elegidos por la mayoría, ejerciendo así un poder que, en ese punto concreto, opera *contra* la mayoría y sin el respaldo directo del voto popular.

Bickel no concluye que el control judicial deba abandonarse: sostiene que se trata de una *dificultad* que debe administrarse con prudencia, y desarrolla la idea de las “virtudes pasivas”: mecanismos procesales (por ejemplo, no tratar cuestiones políticas no justi-

ciables, o esperar a que un caso esté suficientemente “maduro”) mediante los cuales la propia Corte puede evitar pronunciarse que sobre cuestiones que la enfrentarían innecesariamente con las mayorías políticas, reservando su intervención más fuerte para los casos en que resulte verdaderamente indispensable.

4.2. La respuesta de Ely: la teoría del refuerzo de representación

El cronograma indica como bibliografía especial de este punto a John Hart Ely, *Democracia y desconfianza*. El desarrollo que sigue sintetiza esa obra a partir de fuentes académicas secundarias, dado que los apuntes de clase no registraban su contenido.

El constitucionalista norteamericano John Hart Ely propuso, en *Democracy and Distrust* (1980), una respuesta a la dificultad contramayoritaria que no niega el problema, pero busca reformularlo: si el control judicial se ejerciera para imponer los valores sustantivos preferidos por los jueces (qué es una vida buena, qué política económica es correcta), efectivamente usurparía el lugar de las mayorías democráticas. Pero si el control judicial se concentra, en cambio, en **garantizar que el propio proceso democrático funcione correctamente** —que los canales de participación y de cambio político estén abiertos, y que las minorías no queden sistemáticamente excluidas de ellos—, entonces los jueces no están sustituyendo a la democracia: están *reforzándola*.

Propuesta de John Hart Ely según la cual el control judicial de constitucionalidad se legitima, frente a la objeción contramayoritaria, cuando se dirige a desbloquear o a corregir fallas del propio proceso político-representativo: (i) cuando quienes están en el poder distorsionan los canales de cambio político para perpetuarse (por ejemplo, restringiendo el voto o la competencia electoral), o (ii) cuando una mayoría sistemáticamente perjudica a una minoría discreta e insular sin que exista un mecanismo político realista para que esa minoría se defienda a sí misma. En ambos casos, el juez no reemplaza el juicio de valor de la mayoría: repara una falla en el mecanismo por el cual esa mayoría se forma y decide.

4.2.1. La nota al pie n.º 4 de *Carolene Products*

El punto de partida doctrinal de Ely es un párrafo del fallo *United States v. Carolene Products Co.* (Corte Suprema de EE. UU., 1938), redactado por el juez Harlan Fiske Stone: técnicamente un *obiter dictum* (véase Capítulo 1), pero que se convirtió en una de las notas al pie más influyentes del derecho constitucional comparado. Ese párrafo sugiere que la presunción habitual de constitucionalidad de las leyes debe ceder a un escrutinio judicial más estricto en tres supuestos: cuando la norma restringe directamente el propio proceso político (por ejemplo, el derecho al voto); cuando distorsiona los canales de refor-

ma legislativa que permitirían corregir una legislación indeseable por vías democráticas; o cuando perjudica a lo que la nota llama “**minorías discretas e insulares**”.

Grupos minoritarios —definidos, por ejemplo, por su religión, su origen étnico o nacional, o rasgos análogos— que se encuentran aislados del proceso político ordinario: por su tamaño reducido, por los prejuicios que enfrentan o por la dificultad para construir alianzas con otros grupos, no logran hacerse oír ni defender sus intereses a través de los mecanismos habituales de la democracia mayoritaria (el voto, el lobby, la formación de coaliciones). Frente a ellas, el proceso político en el que habitualmente se confía para proteger a las minorías deja de funcionar, y se justifica una revisión judicial más exigente.

Relación con las categorías sospechosas. Esta misma lógica reaparece, en el derecho argentino, bajo la doctrina de las **categorías sospechosas** (desarrollada en el Capítulo 13 a propósito de la libertad religiosa): cuando una norma distingue por motivos como la religión, el origen nacional o rasgos análogos, se invierte la presunción de legitimidad de la ley, exigiéndose al Estado que demuestre su razonabilidad. Es la misma preocupación por las minorías discretas e insulares, trasladada a una técnica de control judicial concreta.

4.3. El poder judicial y los procesos políticos: *Baker v. Carr*

El cronograma vincula esta unidad con el fallo *Baker v. Carr* (Corte Suprema de los Estados Unidos, 1962), en el que la Corte admitió, por primera vez, que los tribunales federales podían revisar judicialmente la manera en que los estados trazaban sus distritos electorales (la llamada “malapportionment”), rechazando la idea de que se tratara de una “cuestión política no justiciable” ajena al control judicial. El fallo ilustra exactamente el segundo tipo de falla que identifica Ely: cuando quienes están en el poder distorsionan las propias reglas del proceso electoral para perpetuarse, ese no es un tema que la mayoría pueda corregirse a sí misma por la vía ordinaria —porque son, precisamente, los beneficiarios de la distorsión quienes controlan el proceso legislativo—, y allí se justifica la intervención judicial: no para imponer un resultado electoral determinado, sino para reabrir el propio canal de cambio político.

4.4. Síntesis: cómo se articula la objeción contramayoritaria con su respuesta

Cuadro 4.1: La dificultad contramayoritaria y la respuesta de Ely

Elemento	Contenido
Objeción (Bickel)	El control judicial de constitucionalidad es una fuerza contramayoritaria: jueces no electos invalidan leyes de representantes electos.
Respuesta (Ely)	El control judicial se legitima cuando repara fallas del propio proceso democrático: canales de participación bloqueados, o perjuicio sistemático a minorías discretas e insulares que no pueden defenderse por la vía política ordinaria.
Fundamento doctrinal	Nota al pie n.º 4 de <i>Carolene Products</i> (1938), técnicamente un <i>obiter dictum</i> que se volvió doctrina central.
Aplicación jurisprudencial	<i>Baker v. Carr</i> (1962): revisión judicial de la distribución de distritos electorales, por afectar el propio proceso de representación.
Proyección en el derecho argentino	La doctrina de las categorías sospechosas (Capítulo 13), que invierte la carga de la prueba de razonabilidad cuando una norma distingue por religión, origen u otros rasgos sensibles.

El Poder Judicial es contramayoritario porque sus integrantes no son elegidos por el voto popular —o lo son solo de manera muy indirecta— y, sin embargo, pueden invalidar leyes sancionadas por los representantes de la mayoría (Bickel). Esta tensión no elimina la legitimidad del control judicial, pero exige justificarlo: la respuesta más influyente es la de Ely, para quien los jueces refuerzan —en lugar de reemplazar— a la democracia cuando intervienen para destrabar el propio proceso político (por ejemplo, frente a distorsiones electorales, como en *Baker v. Carr*) o para proteger a minorías discretas e insulares que no logran hacerse oír por los canales políticos ordinarios (nota 4 de *Carolene Products*). En ambos supuestos, el juez no impone su propia preferencia de valores: corrige una falla del mecanismo por el cual la propia mayoría se forma y decide.

4.5. Cuadro Cornell: el Poder Judicial contramayoritario

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la dificultad contramayoritaria?	La tensión, señalada por Bickel, entre un Poder Judicial no electo y su facultad de invalidar leyes dictadas por representantes elegidos por la mayoría.
¿Cómo responde Ely a esta dificultad?	Sosteniendo que el control judicial se legitima cuando refuerza el propio proceso democrático: destrabando canales de participación bloqueados o protegiendo a minorías discretas e insulares.
¿Qué es la nota 4 de <i>Carolene Products</i> ?	Un <i>obiter dictum</i> de 1938 que enumeró los supuestos en que se justifica un escrutinio judicial más estricto, y que se convirtió en el fundamento doctrinal de la teoría de Ely.
¿Qué son las minorías discretas e insulares?	Grupos minoritarios aislados del proceso político ordinario, que no logran defender sus intereses por los mecanismos habituales de la democracia mayoritaria.
¿Qué mostró <i>Baker v. Carr</i> ?	Que los tribunales pueden revisar la distribución de distritos electorales, porque esa distorsión no puede corregirse por la vía política ordinaria cuando son sus propios beneficiarios quienes controlan el proceso legislativo.

Resumen: el Poder Judicial es contramayoritario porque invalida, sin mandato electoral directo, decisiones de los poderes representativos. Bickel plantea el problema; Ely ofrece la respuesta más influyente: el control judicial se legitima cuando repara fallas del propio proceso democrático —participación bloqueada o minorías discretas e insulares desprotegidas—, en lugar de imponer valores sustantivos ajenos a la decisión mayoritaria.

Parte III

El recurso extraordinario federal

Pregunta 5

Cuestión federal simple o compleja (directa e indirecta)

5.1. Ubicación del tema: el corazón del recurso extraordinario

El recurso extraordinario federal (REF) es la vía por la cual una cuestión constitucional llega, en última instancia, a la Corte Suprema. Su régimen general —requisitos comunes y propios, sentencia definitiva, plazos— se desarrolla en el Capítulo 8. Pero antes de entrar en esos requisitos, es imprescindible comprender su núcleo conceptual: la existencia de una **cuestión federal**.

El corazón de los requisitos del recurso extraordinario está en la existencia de una cuestión federal. El recurso procede formalmente contra sentencias definitivas o asimilables (Capítulo 8), pero, desde el punto de vista sustancial, procede siempre que exista una controversia jurídica en la que esté en juego el alcance de una norma federal o un conflicto entre normas de distinta jerarquía.

La Ley 48 establece la distinción, hoy clásica, entre cuestión federal **simple** y **compleja**, y esta última se subdivide, a su vez, en **directa** e **indirecta**.

5.2. Cuestión federal simple

Controversia en la que está en juego la interpretación de la ley, de la Constitución o de un tratado: se discute cuál es el verdadero alcance de una norma federal, sin que exista un conflicto entre dos normas de distinta jerarquía.

Si para resolver un caso es necesario desentrañar qué alcance corresponde darle al concepto de “indemnización plena”, previsto en una norma federal, se trata de una cuestión federal simple: no hay dos normas en pugna, sino una sola cuyo sentido exacto debe determinarse.

5.3. Cuestión federal compleja: directa e indirecta

A diferencia de la simple, en la cuestión federal compleja existe un **conflicto normativo** entre dos o más normas.

Cuadro 5.1: Cuestión federal compleja directa e indirecta

Tipo	Normas en conflicto	Ejemplo
Compleja directa	La Constitución Nacional y una norma de rango inferior	Una ley o un decreto que contradicen directamente una disposición constitucional
Compleja indirecta	Dos o más normas inferiores a la Constitución, entre sí	Una norma provincial que contradice una ley del Congreso, o un tratado sin jerarquía constitucional, sin que la Constitución esté directamente en pugna

Un punto que suele generar confusión es el de los tratados internacionales. Los tratados con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 CN) forman parte de la Constitución a estos efectos: si la controversia involucra a uno de esos tratados frente a una norma inferior, se trata de una cuestión federal **compleja directa**. Si, en cambio, involucra a un tratado sin jerarquía constitucional —por ejemplo, un tratado del Mercosur— frente a una ley nacional, se trata de una cuestión federal **compleja indirecta**, porque ambas normas son inferiores a la Constitución y ninguna de ellas es, en sí misma, la Constitución.

5.4. Elementos adicionales: decisión contraria y relación directa e inmediata

Además de encuadrar el tipo de cuestión federal, dos requisitos adicionales resultan indispensables:

Para que el recurso extraordinario sea procedente, la decisión impugnada debe ser contraria al derecho federal invocado por quien recurre. Si la sentencia previa resolvió

aplicando correctamente la prelación constitucional (por ejemplo, haciendo prevalecer una norma federal sobre una provincial, tal como la propia Constitución lo exige), no hay cuestión constitucional en juego, porque la sentencia no es contraria al derecho federal: lo aplicó correctamente.

La resolución de la cuestión federal debe tener una relación directa con la decisión del pleito; no puede tratarse de una controversia meramente conjetural o académica, desconectada del resultado concreto del proceso.

¿Es obligatorio clasificar la cuestión federal? No es un requisito intrínseco de admisibilidad etiquetar la cuestión como simple, compleja, directa o indirecta: esa clasificación es una herramienta argumentativa —útil para ordenar el planteo— pero lo verdaderamente indispensable es demostrar con precisión cuál es el derecho federal vulnerado. Las categorías, además, no son puras ni excluyentes: un mismo caso puede combinar, en parte, una controversia sobre el alcance de una norma y, en parte, una colisión normativa propiamente dicha.

5.5. Cuadro Cornell: cuestión federal

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es una cuestión federal simple?	La controversia sobre el alcance de una norma federal, sin colisión con otra norma.
¿Qué diferencia a la cuestión federal compleja directa de la indirecta?	En la directa, la Constitución colisiona con una norma inferior; en la indirecta, colisionan dos o más normas inferiores entre sí.
¿Qué rol cumplen los tratados con jerarquía constitucional en esta clasificación?	Se equiparan a la Constitución: si están en pugna con una norma inferior, la cuestión es compleja directa.
¿Qué es la “decisión contraria al derecho federal invocado”?	El requisito de que la sentencia impugnada haya resuelto en contra del derecho federal que se invoca, y no simplemente aplicado correctamente la prelación normativa.
¿Es obligatorio clasificar la cuestión federal?	No; lo esencial es demostrar cuál es el derecho federal vulnerado.

Resumen: el núcleo del recurso extraordinario es la cuestión federal: simple cuando se discute la interpretación de una norma federal; compleja —directa o indirecta— cuando hay colisión normativa, según que la Constitución esté o no directamente involucrada. La clasificación es una herramienta argumentativa; lo decisivo es siempre demostrar el derecho federal vulnerado y su relación directa e inmediata con el resultado del pleito.

Pregunta 6

Arbitrariedad de sentencia. Supuestos y alcance de la revisión

6.1. Una vía de revisión más allá de la cuestión federal

Además de la cuestión federal desarrollada en el Capítulo 5, la jurisprudencia de la Corte Suprema construyó, sin recepción legal expresa, otra vía por la cual es posible acudir en revisión ante ella aun cuando no se configure una típica cuestión federal.

Doctrina de creación pretoriana, desarrollada por la Corte Suprema desde el siglo XIX, mediante la cual se atribuye a la Corte un carácter revisor de las sentencias de tribunales inferiores aun cuando no estén configurados los presupuestos de una cuestión federal típica, en aquellos casos en que las conclusiones de la sentencia impugnada resultan contrarias a la sana crítica y al principio de razonabilidad. Se engloba bajo este nombre un conjunto de supuestos que deben entenderse siempre como una ruptura de la cadena racional y lógica de la actividad jurisdiccional.

A diferencia de la cuestión federal —regulada por la Ley 48—, la arbitrariedad de sentencia no tiene una recepción legal específica: funciona como una válvula de escape de creación jurisprudencial. La Corte interviene cuando detecta un “ruido” en la racionalidad de la decisión judicial, recurriendo con frecuencia también al concepto de razonabilidad. Puede presentarse incluso en cuestiones de derecho común, ajenas en principio a la competencia de la Corte, funcionando entonces como un salvoconducto excepcional para lograr su revisión.

6.2. Supuestos de arbitrariedad

6.2.1. Errores en la valoración de la prueba

Un testigo situado en tiempo y espacio en el lugar de los hechos, calificado y sin circunstancias que generen demérito de su declaración, es deliberadamente omitido en la decisión judicial. Ese tipo de omisión configura un presupuesto de arbitrariedad. Otros supuestos análogos: una prueba pericial no debidamente merituada, o la consideración exclusiva de una prueba que adolece de errores graves.

6.2.2. Errores en el encuadramiento jurídico

Cuadro 6.1: Supuestos de incorrecto encuadramiento jurídico

Supuesto	Descripción
Marco jurídico inaplicable	Prescindir, por ejemplo, de los principios de la ley de defensa del consumidor en una relación de consumo
Ley no vigente	Aplicar una ley antes de su entrada en vigencia, o una ley ya derogada
Ausencia de fundamentación	Brindar una fundamentación totalmente ajena a la resolución de la litis

6.2.3. Violación del principio de congruencia

Resolución en más: se demanda por daños y perjuicios reclamando lucro cesante y daño emergente, y la sentencia agrega además la pérdida de chance, no solicitada. **Resolución en menos:** se solicita la nulidad de un acto administrativo y una indemnización; la sentencia hace lugar a la nulidad, pero no se adentra en la indemnización pedida. **Legitimación indebida:** se solicita la citación de un tercero solo con ese carácter, y la sentencia resuelve una condena en su contra.

6.2.4. Exceso del tribunal de Cámara respecto de los agravios

Cuando existe doble instancia, la instancia revisora debe estar estrictamente delimitada por el ámbito de los agravios expresados. Todo lo que no fue objeto de una expresión de agravios concreta precluye, es decir, queda firme. Si la Cámara trata elementos que no fueron objeto de impugnación, rompe el orden lógico de su compe-

tencia y da lugar a la arbitrariedad de sentencia.

6.3. Alcance de la revisión: honorarios, intereses y coexistencia con la cuestión federal

Las regulaciones de honorarios y de intereses no motivan, en principio, la intervención de la Corte, porque no está en juego una cuestión federal; pero si están fijados de manera irrazonable —violando la norma procesal aplicable, o por una capitalización derivada de un incorrecto encuadramiento jurídico—, la Corte puede intervenir por la vía de la arbitrariedad, y de hecho lo ha hecho en numerosos casos en materia laboral.

Cuestión federal y arbitrariedad de sentencia no son compartimentos excluyentes: pueden convivir en una misma apelación, con lo cual el campo de revisión de la Corte resulta, en los hechos, todavía más amplio que si solo existiera la vía de la cuestión federal.

6.4. Cuadro Cornell: arbitrariedad de sentencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la doctrina de la arbitrariedad de sentencia?	Una doctrina de creación jurisprudencial —no regulada por ley, a diferencia de la cuestión federal— por la cual la Corte revisa sentencias inferiores cuando hay una ruptura de la cadena racional y lógica de la decisión, aun sin cuestión federal.
¿Qué errores en la valoración de la prueba habilitan la arbitrariedad?	La omisión deliberada de una prueba pertinente y clave, una prueba pericial no merituada o la consideración exclusiva de una prueba con errores graves.
¿Cómo se viola el principio de congruencia?	Resolviendo más de lo pedido, menos de lo pedido, o condenando a un tercero citado solo con ese carácter.
¿Puede la Corte intervenir en honorarios e intereses?	Sí, excepcionalmente, cuando están fijados de forma irrazonable, aunque a priori no susciten cuestión federal.
¿Pueden coexistir cuestión federal y arbitrariedad?	Sí, en una misma apelación, ampliando el campo de revisión de la Corte.

Resumen: la arbitrariedad de sentencia es una válvula de escape jurisprudencial que permite a la Corte revisar sentencias de derecho común sin cuestión federal, cuando se rompe la cadena racional de la decisión: errores graves de prueba, incorrecto encuadramiento jurídico, falta de fundamentación, incongruencia o exceso de la Cámara sobre los agravios. Puede coexistir con una cuestión federal y debe invocarse señalando con precisión el error.

Pregunta 7

Control de constitucionalidad de oficio. Fundamentos y precedentes

7.1. Concepto y fundamento

La Corte Suprema ha aceptado la declaración de inconstitucionalidad de oficio, es decir, aun cuando ninguna de las partes haya invocado expresamente la invalidez constitucional de una norma. Se la concibe como un deber del órgano jurisdiccional, no como una mera facultad discrecional.

Principio según el cual “el juez conoce el derecho”. Habilita al tribunal a aplicar las normas jurídicas que correspondan al caso —incluida su eventual inconstitucionalidad— aun cuando las partes no las hayan invocado expresamente, porque calificar jurídicamente los hechos alegados es una función propia del juez, no de las partes.

A partir del precedente “Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Provincia de Tucumán” (CSJN, 2001), la Corte sostuvo que los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma, aun cuando ninguna de las partes lo haya solicitado expresamente, sin que ello implique una violación del derecho de defensa en juicio ni un exceso de las facultades jurisdiccionales. La Corte no limitó esta posibilidad a determinadas materias: la sostuvo como un principio general, aplicable a cualquier tipo de proceso.

Los fundamentos de esta facultad son tres: el principio *iura novit curia*; la competencia y el deber judicial de aplicar el derecho y de proteger la supremacía de la Constitución, aun sin petición expresa de parte; y la conclusión de que, por ese solo hecho, no hay violación del derecho de defensa de las partes, porque estas ya tuvieron oportunidad de discutir los hechos y la pretensión de fondo.

7.2. El límite: la congruencia con la pretensión de la parte

Existe, sin embargo, un límite fundamental: la eventual declaración de invalidez debe ser coincidente con la pretensión jurídica de la parte actora, tanto al demandar como

al recurrir. El tribunal puede suplir la invocación del derecho aplicable, pero no puede resolver más de lo que fue efectivamente pedido.

Un trabajador demanda una indemnización por despido conforme a los topes legales vigentes. ¿Puede el juez declarar de oficio la inconstitucionalidad de esos topes y otorgar una suma mayor a la reclamada? La respuesta es no, porque el juez estaría yendo más allá de lo pedido, lo que sí constituye una violación del debido proceso: no por declarar de oficio la invalidez de la norma, sino por conceder más de lo solicitado por la parte.

La declaración de invalidez de una norma puede realizarse de oficio, pero siempre que sea coincidente con la pretensión jurídica de la parte actora. Si el juez va más allá de lo que la parte pidió, es allí —y no en la sola declaración de oficio— donde puede configurarse una violación del derecho de defensa.

7.3. Precedentes históricos

Marbury v. Madison y *Sojo* (desarrollados en el Capítulo 2) son, en cierto sentido, antecedentes remotos de esta doctrina: en ambos casos la invalidez —o, en *Sojo*, la cuestión de competencia— fue resuelta por el tribunal sin que la parte hubiera argumentado estrictamente en esos términos, mostrando un camino largo y relativamente pacífico hacia la doctrina actual. Otro precedente relevante es el caso de la “Municipalidad de la Capital c/ Elortondo”, referido a la expropiación, considerado uno de los primeros fallos en que la Corte se inmiscuye en la regulación económica de contratos de derecho privado, también bajo la condición de que la invalidación resultara congruente con la pretensión jurídica de alguna de las partes.

7.4. Vínculo con el recurso extraordinario federal

La facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio, si bien se estudia como un tema autónomo, con frecuencia se activa en el propio trámite del recurso extraordinario: el juez, al conocer el derecho, puede advertir una colisión normativa no planteada expresamente por las partes, siempre que la declaración resulte coincidente con la pretensión jurídica deducida en el proceso.

7.5. Cuadro Cornell: inconstitucionalidad de oficio

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la declaración de inconstitucionalidad de oficio?	La facultad, concebida como deber del órgano jurisdiccional, de declarar la invalidez constitucional de una norma aun cuando ninguna de las partes lo haya solicitado expresamente, a partir de “Mill de Pereyra” (2001).
¿En qué principio se funda y por qué no viola el derecho de defensa?	En el principio <i>iura novit curia</i> : el juez conoce el derecho. Al tratarse de una calificación jurídica y no de nuevos hechos, en principio no hay violación del derecho de defensa.
¿Cuál es el límite de esta facultad?	La pretensión de la parte: el tribunal puede suplir la invocación del derecho, pero no puede resolver por encima de lo que la parte solicitó.
¿Qué precedentes se vinculan con esta doctrina?	<i>Marbury v. Madison</i> y <i>Sojo</i> , donde la invalidez se resolvió sin haber sido invocada en esos términos exactos; y el caso “Elortondo”, sobre expropiación.
Resumen: los tribunales pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma en virtud del principio <i>iura novit curia</i> , sin que ello viole el derecho de defensa, siempre que la declaración sea congruente con la pretensión de la parte al demandar y al recurrir.	

Pregunta 8

Recurso extraordinario: requisitos formales, comunes y propios

8.1. El recurso extraordinario como mecanismo de impugnación

El recurso extraordinario federal es el mecanismo procesal, regulado por la Ley 48, por el cual una cuestión constitucional resuelta por un tribunal superior de una causa —provincial o nacional— puede llegar en revisión hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la vía de acceso ordinaria a la Corte cuando existe una cuestión federal (Capítulo 5).

8.1.1. Requisitos formales

La Corte reglamentó minuciosamente la forma del recurso mediante la **Acordada 4/2007**, que fija reglas estrictas de admisibilidad formal: una extensión máxima de 40 páginas, tipografía y espaciado determinados, una carátula con un resumen del caso y de la cuestión federal invocada, entre otros recaudos. El incumplimiento de estos requisitos formales puede llevar al rechazo del recurso sin que se examine su fondo.

El recurso debe interponerse ante el mismo tribunal que dictó la sentencia impugnada (el “tribunal superior de la causa”), dentro del plazo de diez días desde la notificación de la sentencia. Un requisito adicional, exigido por la jurisprudencia, es el de la **reserva**: la cuestión federal debe haberse planteado ya en cada instancia anterior del proceso, en la primera oportunidad procesal posible; no puede introducirse por primera vez recién al interponer el recurso extraordinario.

8.1.2. Requisitos comunes a todo recurso judicial

Perjuicio acreditado en cabeza de quien impugna. La decisión cuestionada debe generar, inevitablemente, un perjuicio concreto y actual a quien recurre; no puede ser conjetural ni referido a un daño meramente futuro y eventual.

Debe existir, además, un **proceso judicial en trámite** —en contraposición, por ejemplo, a una instancia meramente administrativa—, presupuesto ineludible para la procedencia de cualquier recurso, incluido el extraordinario.

8.1.3. Requisitos propios: sentencia definitiva o asimilable

El recurso extraordinario, en principio, no está previsto para actos interlocutorios ni para medidas cautelares. Debe tratarse de sentencias que ponen fin al proceso, o asimilables a definitivas: aquellas en las que ya no hay marcha atrás, o solo hay marcha hacia adelante, generando un perjuicio irreparable si no se revisan de inmediato.

Las medidas cautelares (desarrolladas en profundidad en el Capítulo 10) son, por definición, provisionales: no son sentencias, porque cualquier medida cautelar debe luego ser ratificada por la decisión de fondo. Por eso, en principio, el recurso extraordinario no procede contra ellas. Excepcionalmente, en casos de especial trascendencia, gravedad institucional o que involucran una pluralidad de sujetos con fuerte impacto social, la Corte se aboca a recursos extraordinarios interpuestos contra medidas cautelares, cuando estas pueden generar perjuicios irreparables.

Cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (“Ley de Medios”), el grupo empresario afectado la impugnó e interpuso una medida cautelar para suspender su aplicación. La Corte abordó el recurso extraordinario pese a estar dirigido contra una cautelar, por tratarse de una ley recientemente dictada con un enorme efecto social e institucional.

Cuadro 8.1: Síntesis de los requisitos del recurso extraordinario

Tipo de requisito	Contenido
Formales	Acordada 4/2007: extensión máxima de 40 páginas, forma de la carátula y del escrito; plazo de 10 días; reserva del caso federal en cada instancia anterior
Comunes	Gravamen (perjuicio actual y concreto) y existencia de un proceso judicial en trámite
Propios	Sentencia definitiva o asimilable; existencia de una cuestión federal (Capítulo 5), con relación directa e inmediata y decisión contraria al derecho federal invocado

Efectos de la concesión y del rechazo. Si el tribunal concede el recurso, la concesión tiene, en principio, efecto suspensivo sobre la ejecución de la sentencia. Si el tribunal lo rechaza, no hay efecto suspensivo: la sentencia queda en condiciones de ejecutarse, sin perjuicio de que la parte recurra ese rechazo mediante la queja (Capítulo 9).

8.2. Cuadro Cornell: requisitos del recurso extraordinario

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué regula la Acordada 4/2007?	Los requisitos formales del recurso extraordinario: extensión máxima, forma de la carátula y del escrito.
¿Qué exigen los requisitos comunes a todo recurso?	Un gravamen o perjuicio actual y concreto, y la existencia de un proceso judicial en trámite.
¿Qué tipo de resoluciones habilita el recurso extraordinario?	Sentencias definitivas o asimilables a definitivas; en principio no medidas cautelares, salvo gravedad institucional o fuerte impacto social.
¿Qué es la “reserva” del caso federal?	La exigencia de haber planteado la cuestión federal en cada instancia anterior, en la primera oportunidad procesal posible.
¿Qué efecto tiene la concesión del recurso?	Efecto suspensivo, en principio, sobre la ejecución de la sentencia impugnada.
Resumen: el recurso extraordinario exige requisitos formales (Acordada 4/2007, plazo de diez días, reserva del caso federal), requisitos comunes (gravamen y proceso judicial en trámite) y requisitos propios (sentencia definitiva o asimilable y cuestión federal, con relación directa e inmediata). Su concesión suspende, en principio, la ejecución de la sentencia impugnada.	

Pregunta 9

Recurso de queja

9.1. Cuándo procede

Recurso que interpone la parte que dedujo el recurso extraordinario, si el tribunal superior de la causa lo rechaza y ella quiere insistir en su tratamiento. Se interpone directamente ante la Corte Suprema, sin pasar por el tribunal que dictó el rechazo.

Mientras que el recurso extraordinario no está sujeto al pago de una tasa, la queja sí requiere un depósito previo (salvo excepciones, como la del trabajador en procesos laborales); si la queja no es admitida, ese monto se destina a la biblioteca de la Corte. El plazo para interponerla es de cinco días desde la notificación del rechazo, ampliable según la tabla de distancias para quien tiene su domicilio en el interior del país, en un escrito de hasta diez páginas.

Cuadro 9.1: Recurso extraordinario y recurso de queja

	Recurso extraordinario	Queja
Ante quién	El mismo tribunal que dictó el acto impugnado	Directamente ante la Corte Suprema
Costo	No se cobra tasa	Requiere depósito, salvo excepciones
Extensión máxima	40 páginas	10 páginas
Plazo	10 días	5 días (más tabla de distancias)
Cuándo procede	Contra sentencia definitiva o asimismo	Cuando el recurso extraordinario fue rechazado

9.2. Objeto de la queja y efectos

El centro de la argumentación de la queja consiste en demostrar que el rechazo del recurso extraordinario fue arbitrario: infundado, ilegítimo o irrazonable. A diferencia del recurso extraordinario concedido, la mera interposición de la queja no suspende la ejecución de la

sentencia, porque la Corte la resuelve *inaudita parte* (sin dar traslado a la contraparte). Para intentar suspender la ejecución mientras la queja tramita, la única vía disponible es solicitar una medida cautelar, sustentada en la verosimilitud del derecho a interponer el recurso extraordinario, tema que se desarrolla en el Capítulo 10.

Relación con el control de constitucionalidad de oficio. Como se explicó en el Capítulo 7, la facultad de declarar la inconstitucionalidad de oficio también puede activarse en el marco de una queja: la Corte, al resolverla, puede advertir una colisión normativa no planteada expresamente, siempre que la declaración sea congruente con la pretensión deducida en el proceso.

9.3. Cuadro Cornell: recurso de queja

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el recurso de queja?	El recurso que se interpone directamente ante la Corte Suprema cuando el tribunal superior de la causa rechazó el recurso extraordinario.
¿Qué plazo y extensión tiene?	Cinco días desde la notificación del rechazo (más tabla de distancias), en un escrito de hasta diez páginas.
¿Requiere depósito?	Sí, salvo excepciones como la del trabajador; si se rechaza, el monto se destina a la biblioteca de la Corte.
¿Suspende la ejecución de la sentencia?	No, a diferencia del recurso extraordinario concedido; la Corte resuelve <i>inaudita parte</i> .
¿Cómo se puede suspender la ejecución mientras tramita la queja?	Solicitando una medida cautelar fundada en la verosimilitud del derecho a interponer el recurso extraordinario.
Resumen: la queja es la vía para insistir ante la propia Corte Suprema cuando el recurso extraordinario fue rechazado por el tribunal inferior. Exige depósito previo, un plazo breve de cinco días y un escrito de hasta diez páginas, y su objeto es demostrar que el rechazo fue arbitrario. A diferencia del recurso extraordinario concedido, no suspende por sí sola la ejecución de la sentencia.	

Pregunta 10

Medida cautelar. Presupuestos. Su relación con el recurso extraordinario

10.1. Concepto y función

Medida provisional, con un límite temporal, que no es una decisión definitiva ni hace cosa juzgada. Puede solicitarse en cualquier momento del proceso, incluso antes de su inicio. Su función es dar validez, ejecutoriedad y virtualidad a la eventual decisión sobre el fondo del asunto, evitando que el mero transcurso del tiempo genere perjuicios irreparables mientras el proceso continúa.

10.2. Los tres presupuestos clásicos

1. **Verosimilitud en el derecho:** que el planteo tenga asidero jurídico razonable; no se exige una certeza absoluta, sino un “humo del buen derecho” suficiente para habilitar una decisión provisoria.
2. **Peligro en la demora:** la demostración de que el transcurso del tiempo puede hacer perder un derecho, generando un perjuicio irreparable o de muy dificultosa reparación posterior.
3. **Contracautela:** la garantía que debe prestar quien solicita la medida, para responder por los eventuales daños que su dictado pueda causar a la contraparte si finalmente la pretensión de fondo no prospera.

Si una persona necesita acceder a una prestación médica de alta complejidad, puede solicitar cautelarmente la prestación mientras se discute si estaba a cargo de la obra social o de la empresa de medicina prepaga: de lo contrario, el mero transcurso del tiempo del proceso puede generar un daño irreparable en su salud.

Vasos comunicantes. Verosimilitud en el derecho y peligro en la demora se relacionan de forma inversamente proporcional: cuanto mayor es la verosimilitud del derecho invocado, menos exigente puede ser la demostración del peligro en la demora, y viceversa. Ninguno de los dos requisitos puede faltar por completo: el tribunal los pondera siempre en conjunto.

10.3. Relación con el recurso extraordinario

Como se adelantó en el Capítulo 8, el recurso extraordinario no procede, en principio, contra resoluciones cautelares, precisamente porque no son sentencias definitivas. Sin embargo, cuando la cautelar tiene efectos generales, excede el interés puntual de las partes y puede configurar un agravio irreparable, muy excepcionalmente se habilita el recurso extraordinario en su contra —tal como ocurrió en el caso de la Ley de Medios, o en controversias sobre el financiamiento de la universidad pública, donde el fuero contencioso administrativo hizo lugar a una cautelar pero habilitó su revisión por la Corte dada la delicadeza política del caso—.

Contra el Estado Nacional rige, además, un régimen especial: la Ley 26.854 prevé un traslado previo, urgente y por un plazo breve, a la autoridad pública demandada, antes de resolver sobre la cautelar, a diferencia de la regla general de resolución *inaudita parte* que rige para la queja (Capítulo 9).

10.4. Cuadro Cornell: medida cautelar

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es una medida cautelar?	Una medida provisional, sin efecto de cosa juzgada, destinada a asegurar que la eventual decisión de fondo pueda cumplirse efectivamente.
¿Cuáles son sus tres presupuestos clásicos?	Verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y contracautela.
¿Cómo se relacionan verosimilitud y peligro en la demora?	De forma inversamente proporcional: a mayor verosimilitud, menor exigencia de peligro en la demora, y viceversa.
¿Procede el recurso extraordinario contra una cautelar?	En principio no, por no ser sentencia definitiva; excepcionalmente sí, cuando hay gravedad institucional o efectos generales con perjuicio irreparable.
¿Qué régimen especial rige contra el Estado Nacional?	La Ley 26.854, que exige un traslado previo y urgente a la autoridad pública antes de resolver la cautelar.

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
----------------------------	--------------------

Resumen: la medida cautelar asegura la eficacia práctica del proceso mientras se resuelve el fondo, sobre la base de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y contracautela. Aunque el recurso extraordinario no procede, en principio, contra ella por no ser sentencia definitiva, la gravedad institucional o el impacto general de la medida pueden habilitar excepcionalmente su revisión por la Corte.	
--	--

Pregunta 11

Per saltum

11.1. Concepto y marco normativo

Figura prevista en los artículos 257 bis y 257 ter del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite, en el ámbito federal, pasar directamente de la primera instancia a la Corte Suprema, sin pasar por la cámara de apelaciones, cuando la cuestión debatida sea de notoria gravedad institucional cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y el recurso constituya el único remedio eficaz para la protección del derecho federal comprometido.

11.2. Requisitos

1. Causa de índole federal.
2. Gravedad institucional que exceda el interés particular de las partes: el caso, en general, debe proyectarse sobre una controversia de enorme relevancia social, porque atañe a muchos sujetos que pueden estar en la misma situación.
3. Riesgo de un perjuicio irreparable si el caso sigue el trámite recursivo ordinario, es decir, si debe pasar primero por la cámara de apelaciones.

Un juez de primera instancia había declarado la inconstitucionalidad de un artículo de una reforma laboral; el gobierno solicitó el *per saltum* frente a la medida cautelar que había suspendido varios artículos de la ley. La Corte rechazó la pretensión al no encontrar acreditada la extrema celeridad invocada, y consideró razonable que la causa siguiera su curso ordinario ante la cámara, que finalmente levantó la suspensión. En un caso similar, referido a una ley de empleo público, la Corte también rechazó el *per saltum* por no encontrar acreditada la gravedad institucional ni el perjuicio irreparable, reafirmando el carácter absolutamente excepcional de esta figura.

El *per saltum* está previsto solo para causas de derecho federal: nunca está en discusión que se salte la instancia de una cámara provincial hacia la Corte provincial, porque todo lo que es materia federal tramita, desde el inicio, ante la justicia federal.

11.3. Cuadro Cornell: *per saltum*

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el <i>per saltum</i> ?	Una figura excepcional (arts. 257 bis y ter CPCCN) que permite saltar la instancia de la cámara federal y acceder directamente a la Corte, en causas de derecho federal con gravedad institucional y riesgo de perjuicio irreparable.
¿Cuáles son sus tres requisitos?	Causa de índole federal, gravedad institucional que exceda a las partes, y riesgo de perjuicio irreparable por el trámite ordinario.
¿Se aplica en causas provinciales?	No; está previsto solo para procesos de derecho federal.
¿Cómo lo trató la Corte en los casos de reforma laboral y empleo público?	Los rechazó en ambos casos, por no encontrar acreditada la extrema gravedad institucional ni el perjuicio irreparable, reafirmando su carácter excepcional.
Resumen: el <i>per saltum</i> es una vía excepcional para llegar directamente a la Corte Suprema sin pasar por la cámara, reservada a causas federales de notoria gravedad institucional con riesgo de perjuicio irreparable. La jurisprudencia lo aplica con suma cautela, como muestran los rechazos en materia de reforma laboral y de empleo público.	

Parte IV

El principio de reserva y los derechos individuales

Pregunta 12

Principio de reserva. Objeción de conciencia

12.1. El artículo 19: el principio de reserva

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

Ámbito de la conducta humana vedado a la regulación normativa: las acciones privadas que no ofenden el orden ni la moral pública ni perjudican a terceros. El Congreso no puede regular conductas que no exteriorizan una afectación a terceros. El punto más complejo de esta garantía consiste en determinar dónde está la veda normativa y cuál es el verdadero umbral en el que las normas no pueden entrometerse.

Es, en palabras de Kelsen, una típica **norma de cerramiento**: brinda un principio interpretativo para entender dónde están las fronteras de la regulación legal, pero no resuelve por sí sola los casos particulares. La Constitución da una idea general, y es la interpretación judicial —caso a caso— la que traza, efectivamente, esa frontera. Entre los campos de aplicación de este principio se destacan la no punición del consumo personal de estupefacientes (doctrina *Bazterrica*, CSJN, 1986), la interrupción del embarazo, la muerte asistida y, en lo que aquí interesa especialmente, la **libertad de conciencia y de religión**, desarrollada en el Capítulo 13.

Relación con la interpretación constitucional. El propio artículo 19 es un buen ejemplo del problema estudiado en el Capítulo 1: una lectura textualista tiende a acotar la interpretación a la literalidad de “orden”, “moral pública” y “perjuicio a terceros”; una lectura no textualista (sea originalista o pragmática) admite proyectar esas expresiones a los valores y problemas actuales.

12.2. La objeción de conciencia

Los apuntes de la cátedra no traían un desarrollo autónomo de la objeción de conciencia como categoría general, aunque mencionaban de modo tangencial la objeción religiosa al servicio militar dentro del capítulo sobre libertad religiosa. El desarrollo que sigue —incluidos los casos “Portillo” y “Bahamondez”— se elaboró a partir de fuentes jurisprudenciales y doctrinarias verificadas (véase la bibliografía final). No fue posible verificar con las fuentes disponibles el contenido ni la carátula exacta de un tercer precedente mencionado en el cronograma de la cátedra bajo el apellido “Sisto”; por prudencia académica, se deja constancia de esa laguna en lugar de completarla con información no verificada.

Derecho de una persona a ser eximida del cumplimiento de un deber legal —o a cumplirlo por una vía alternativa compatible con sus convicciones— cuando ese deber contradice creencias religiosas o morales profundas, serias y acreditadas. Se trata de una tensión entre un derecho constitucional (la libertad de culto y de conciencia) y un deber también de raigambre constitucional o legal, que debe resolverse armonizando ambos extremos y no haciendo prevalecer automáticamente a uno sobre el otro.

La objeción de conciencia se ubica dentro del principio de reserva del artículo 19, en tanto protege un ámbito de convicciones íntimas de la persona, pero se proyecta hacia afuera cuando esas convicciones chocan con un deber jurídico positivo (por ejemplo, el deber de armarse en defensa de la Nación, art. 21 CN, o el deber de someterse a un tratamiento médico). Por eso su reconocimiento constitucional deriva, en la jurisprudencia argentina, de la conjunción entre el artículo 19 (autonomía personal) y el artículo 14 (libertad de culto y de conciencia) de la Constitución Nacional.

12.2.1. El caso “Portillo” (CSJN, 1989)

Alfredo Portillo, de religión católica, fue condenado por no presentarse a cumplir el servicio militar obligatorio (art. 44, Ley 17.531), alegando que sus convicciones religiosas —fundadas en el quinto mandamiento— le impedían portar armas contra otro ser humano. La Corte Suprema, por mayoría (jueces Fayt, Petracchi y Bacqué), reconoció por primera vez en la Argentina el carácter constitucional de la objeción de conciencia, derivándola de la libertad de culto y de conciencia del artículo 14 CN. Sin embargo, no lo eximió lisa y llanamente del servicio: armonizó ese derecho con el deber de armarse en defensa de la Patria y de la Constitución (art. 21 CN), confirmando la obligación de Portillo de cumplir el servicio militar, pero **sin el uso de armas**, en una modalidad compatible con sus convicciones religiosas.

La clave de “Portillo” es la armonización, no la exención automática. Ni los derechos ni los deberes constitucionales son absolutos: obligar a quien profesa una objeción religiosa seria a portar armas lesiona su conciencia, pero eximirlo lisa y llanamente de toda carga pública, sin más, rompería la igualdad en las cargas públicas frente a quienes sí cumplen el servicio en armas. La solución de la Corte fue, por eso, una vía intermedia: mantener la carga, pero adaptar su modo de cumplimiento.

12.2.2. El caso “Bahamondez” (CSJN, 1993)

Marcelo Bahamondez, internado por una hemorragia digestiva, se negó a recibir transfusiones de sangre por ser Testigo de Jehová, religión que las considera pecaminosas. Las instancias inferiores autorizaron la transfusión en contra de su voluntad, calificando su negativa como un “suicidio lentificado”. Al llegar el caso a la Corte Suprema, la situación de hecho ya había cesado (Bahamondez había recibido el alta médica sin haber sido transfundido), por lo que la mayoría declaró la cuestión abstracta. Sin embargo, distintos votos —entre ellos los de los jueces Barra, Fayt, Belluscio y Petracchi— avanzaron sobre el fondo del asunto, sosteniendo que la negativa de un adulto, lúcido, a un tratamiento médico por razones de conciencia religiosa, sin afectación a terceros, se encuentra amparada por el principio de reserva del artículo 19 CN y por la autonomía personal, y que el Estado no puede imponerle el tratamiento contra su voluntad invocando la protección de su propia vida, salvo que existan derechos de terceros comprometidos.

Cuadro 12.1: “Portillo” y “Bahamondez”: dos variantes de objeción de conciencia

	Portillo (1989)	Bahamondez (1993)
Deber en tensión	Servicio militar obligatorio (art. 21 CN)	Deber estatal de tutelar la vida y la salud
Fundamento de la objeción	Libertad de culto y conciencia (art. 14 CN), motivación católica	Libertad de culto y autonomía personal (arts. 14 y 19 CN), motivación como Testigo de Jehová
Solución	Armonización: se mantiene el deber, pero se modifica su modo de cumplimiento (servicio sin armas)	La autonomía del paciente adulto y lúcido prevalece sobre la imposición estatal de un tratamiento, sin afectación de terceros
Aporte doctrinal	Primer reconocimiento constitucional expreso de la objeción de conciencia en la Argentina	Proyección de la objeción de conciencia sobre el derecho a rechazar tratamientos médicos, dentro del principio de reserva

El principio de reserva del artículo 19 CN traza la frontera entre lo que el Estado puede y no puede regular, exigiendo que exista ofensa al orden, a la moral pública o perjuicio a un tercero para que una conducta privada pueda ser objeto de regulación legal. La objeción de conciencia es una proyección de ese principio, combinado con la libertad de culto y de conciencia del artículo 14 CN: protege el derecho de una persona a no cumplir, o a cumplir de un modo alternativo, un deber jurídico que contradice sus convicciones religiosas o morales serias y acreditadas. La Corte Suprema la reconoció por primera vez en “Portillo” (1989), armonizando el deber de armarse en defensa de la Patria con la libertad de conciencia mediante una solución intermedia (servicio sin armas), y la proyectó en “Bahamondez” (1993) hacia el derecho de un adulto lúcido a rechazar un tratamiento médico por motivos religiosos, en tanto no se afecten derechos de terceros. En ambos casos, la objeción de conciencia no opera como una exención automática, sino como un llamado a armonizar el derecho invocado con el deber o interés estatal en juego.

12.3. Cuadro Cornell: principio de reserva y objeción de conciencia

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué establece el artículo 19 CN?	Que las acciones privadas que no ofenden el orden ni la moral pública, ni perjudican a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados.
¿Qué es una “norma de cerramiento”?	En palabras de Kelsen, una norma que traza un principio interpretativo sobre las fronteras de la regulación legal, aplicable caso a caso.
¿Qué es la objeción de conciencia?	El derecho a ser eximido de un deber legal, o a cumplirlo de otro modo, cuando contradice convicciones religiosas o morales serias y acreditadas.
¿Qué resolvió “Portillo” (1989)?	Reconoció por primera vez la objeción de conciencia, armonizando el deber de armarse (art. 21 CN) con la libertad de conciencia (art. 14 CN): servicio militar sin uso de armas.
¿Qué resolvió “Bahamondez” (1993)?	Proyectó la objeción de conciencia sobre el derecho de un adulto lúcido a rechazar tratamientos médicos por motivos religiosos, sin afectación de terceros, dentro del principio de reserva.

Preguntas / palabras clave Notas / respuestas

Resumen: el artículo 19 CN traza la frontera entre lo regulable y lo reservado a la autonomía personal. La objeción de conciencia, construida sobre esa base junto con la libertad de culto del artículo 14 CN, no opera como exención automática de los deberes legales, sino como una armonización entre el deber en juego y la convicción invocada, como muestran “Portillo” (servicio sin armas) y “Bahamondez” (autonomía frente al tratamiento médico).

Pregunta 13

Libertad religiosa

13.1. La Iglesia como persona jurídica de derecho público

El ordenamiento argentino reconoce a la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público, lo que conlleva privilegios como la inmunidad e inembargabilidad de los bienes afectados al culto, extendida también a otras religiones registradas ante la Secretaría de Culto. Originalmente se exigía que el presidente profesara la religión católica, requisito derogado por la reforma constitucional de 1994, que mantuvo, sin embargo, el estatus de la Iglesia como persona jurídica de derecho público. A partir de esa reforma, la idea del sostenimiento del culto católico debe conjugarse inevitablemente con una férrea libertad religiosa y con el principio de no discriminación entre los distintos credos.

El sostenimiento del culto católico se reduce a los aspectos institucionales de configuración de la Iglesia como persona jurídica de derecho público, pero no puede trasladarse a preferencias expresas en la opción religiosa de las personas. La profesión de una religión queda relegada al ámbito de reserva del artículo 19 CN.

13.2. Categorías sospechosas

Regulaciones que establecen diferencias basadas en rasgos como edad, nacionalidad, religión, origen o género. La jurisprudencia de la Corte las somete a un escrutinio más estricto, invirtiendo la presunción de legitimidad de la norma.

Las normas emanadas de competencias legítimas se presumen, en general, válidas y aplicables. Lo que hace la categoría sospechosa es invertir esa carga: la norma se presume, a priori, potencialmente inválida, y es el Estado quien, en el juicio, debe demostrar su legitimidad y razonabilidad.

Relación con el poder judicial contramayoritario. Esta técnica traduce, en el derecho argentino, la misma lógica que Ely desarrolla a propósito de las minorías discretas e insulares (Capítulo 4): cuando una norma distingue por religión u otro rasgo sensible, el grupo afectado suele carecer de peso suficiente en el proceso político ordinario para revertir esa norma por la vía legislativa, lo que justifica un control judicial más exigente.

13.3. El caso de la educación religiosa obligatoria en Salta

Una demanda cuestionó la educación inicial obligatoria en la provincia de Salta, en la que se impartía, en los hechos, catequesis católica bajo la apariencia de una asignatura de “religión a secas”. La asociación demandante sostenía que, al no existir en la práctica una materia alternativa efectiva para quienes se eximían, se generaba una **discriminación indirecta** hacia los alumnos no católicos.

Discriminación indirecta. Lo relevante del caso no era la existencia formal de una opción de exención, sino su ineficacia práctica: los alumnos exentos no recibían una materia alternativa real y quedaban, en los hechos, relegados frente a la mayoría, por lo que la sola previsión formal de una excepción no bastaba para salvar la norma.

La Corte, por mayoría, resolvió que el sistema, tal como estaba implementado, era violatorio de la libertad religiosa, por establecer preferencias y evidenciar una segregación hacia los alumnos que no cursaban la clase de religión, sin ofrecerles una alternativa educativa real. El argumento de la autonomía provincial en materia de educación inicial, invocado por la propia provincia, no fue suficiente para justificar la norma frente a la protección de la libertad religiosa.

13.4. Otros ámbitos de aplicación

13.4.1. Testigos de Jehová y transfusiones de sangre

Como se desarrolló en el Capítulo 12 a propósito de “Bahamondez”, la negativa a recibir transfusiones de sangre por motivos religiosos queda amparada por el principio de reserva y la libertad religiosa, siempre que se trate de una decisión personal, inequívoca y expresada en condiciones de lucidez y libre discernimiento, sin afectación de terceros. Esa voluntad no puede ser suplida, ni siquiera por familiares allegados, cuando la persona está en condiciones de expresarla por sí misma.

13.4.2. Educación en el hogar y comunidades menonitas

La Constitución reconoce que todo habitante es libre de enseñar y de aprender (art. 14 CN), sin exigir que ello ocurra necesariamente en una institución formal. Comunidades religiosas como la menonita han planteado, en distintos países, su derecho a educar a sus hijos según sus propias pautas culturales y religiosas, sin enviarlos a los sistemas de educación básica estatales, siempre que se acredite el cumplimiento de contenidos mínimos obligatorios.

13.4.3. Objeción religiosa al servicio militar

Este ámbito se desarrolla en profundidad en el Capítulo 12 a propósito del caso “Portillo”: religiones que impiden portar armas plantearon, históricamente, tensiones con el servicio militar obligatorio, en un contexto en que ese servicio no era únicamente una prestación de defensa, sino que conllevaba también funciones de sanidad pública.

El principio de reserva (art. 19 CN) constituye el eje común que atraviesa todos estos casos: transfusiones de sangre, educación en el hogar, comunidades menonitas y objeción religiosa al servicio militar. En todos ellos, la pregunta de fondo es la misma que en el Capítulo 12: dónde termina la autonomía personal y dónde empieza el ámbito legítimo de la regulación estatal.

13.5. Cuadro Cornell: libertad religiosa

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué privilegios conlleva el estatus de la Iglesia Católica como persona jurídica de derecho público?	La inmunidad e inembargabilidad de los bienes afectados al culto, extendida a otras religiones registradas ante la Secretaría de Culto.
¿Qué es una categoría sospechosa y qué efecto produce?	Una distinción normativa basada en rasgos como religión, nacionalidad, edad, origen o género, que invierte la presunción de legitimidad: el Estado debe demostrar la razonabilidad de la norma.
¿Cómo se resolvió el caso de educación religiosa en Salta?	La Corte, por mayoría, declaró inconstitucional la asignatura de religión obligatoria en la educación inicial, por generar discriminación indirecta hacia los alumnos no católicos.
¿Qué rige la negativa a transfusiones de sangre por motivos religiosos?	El principio de reserva y la libertad religiosa, siempre que sea una decisión personal, inequívoca y lúcida, no suplible por terceros.
¿Qué eje común atraviesa todos los casos de libertad religiosa?	El principio de reserva del artículo 19 CN.

Preguntas / palabras clave Notas / respuestas

Resumen: el sostenimiento institucional del culto católico convive con la exigencia de neutralidad estatal, reforzada por la doctrina de las categorías sospechosas, que invierte la carga de la prueba cuando una norma distingue por religión u otros rasgos sensibles. Esta lógica se proyecta en el fallo sobre educación religiosa en Salta y en los casos de transfusiones de sangre, educación en el hogar, comunidades menonitas y objeción religiosa al servicio militar, todos anclados en el principio de reserva del artículo 19 CN.

Pregunta 14

Libertad de expresión. Prohibición de censura previa. Doctrina Campillay y doctrina de la real malicia. Derecho de réplica

14.1. La doble dimensión de la libertad de expresión y su importancia democrática

Conforme lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de expresión tiene una **dimensión individual** —el derecho de cada persona a expresar y difundir su pensamiento y sus opiniones— y una **dimensión social o colectiva** —el derecho de la sociedad a recibir información y opiniones, entendida como condición para el funcionamiento del sistema democrático y para la existencia de un verdadero mercado de ideas.

Esta doble dimensión explica por qué la libertad de expresión no se protege únicamente como un derecho individual del emisor, sino como un pilar estructural del sistema democrático en su conjunto: sin un intercambio libre de ideas e información, la ciudadanía no puede formar una opinión pública informada, controlar a sus gobernantes ni participar efectivamente en el proceso político. Por esa razón, en el marco del Pacto de San José de Costa Rica, el estado de la libertad de expresión es uno de los elementos con que la Carta Democrática de la OEA examina si un sistema político efectivamente adhiere a los postulados democráticos. La conexión con el Capítulo 4 es directa: una prensa libre es, junto con elecciones libres, uno de los canales de participación cuyo buen funcionamiento el control judicial está llamado a proteger.

14.2. La prohibición de censura previa

Todo mecanismo de control estatal que impide o condiciona, **antes** de que una expresión se difunda, su publicación o circulación —por ejemplo, exigiendo una autorización previa, o prohibiendo directamente la exhibición o publicación de un contenido—. Se distingue de la responsabilidad ulterior, que sanciona *ex post* las consecuencias jurídicas de una expresión ya difundida.

El artículo 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de “publicar las ideas por la prensa sin censura previa”, y el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe expresamente la censura previa en su artículo 13. El sistema interamericano de derechos humanos es, en este punto, particularmente estricto: el control estatal sobre la expresión debe ser siempre reparador y posterior, nunca preventivo, salvo la única excepción admitida —la protección de menores de edad frente a información sensible o dañina—.

En el caso “La Última Tentación de Cristo” (Corte Interamericana de Derechos Humanos), se condenó a Chile por no asegurar la libertad de expresión y por haber ejercido censura previa al prohibir la exhibición de esa película en su territorio, precisamente por tratarse de un control estatal anterior a la difusión de la obra.

Por qué la censura previa es más grave que la responsabilidad ulterior. Un sistema de responsabilidad ulterior permite que la expresión circule y que la sociedad la conozca, reservando la sanción para después, si corresponde; la censura previa, en cambio, impide que la expresión llegue siquiera a existir en el debate público, lesionando tanto la dimensión individual como la dimensión social de la libertad de expresión.

14.3. La doctrina de la real malicia

De origen norteamericano (*New York Times Co. v. Sullivan*, Corte Suprema de EE. UU., 1964) y adoptada por la Corte argentina: cuando la información se refiere a una persona pública, sujeta a un escrutinio más intenso, el medio de comunicación solo responde por una información inexacta si quien demanda prueba que el medio conocía de antemano la falsedad de la información y, aun así, decidió difundirla (dolo, o cuando menos una negligencia grave en el chequeo de las fuentes). La carga de la prueba recae en quien demanda.

Se exige, entonces, un estándar de exigencia mucho mayor que la simple prueba de la falsedad de lo publicado: debe probarse el conocimiento previo de la no veracidad y, pese a ello, la decisión de avanzar con la difusión. Con el tiempo, la doctrina se ha ido

DOCTRINA CAMPILLAY Y DOCTRINA DE LA REAL MALICIA. DERECHO DE *Derecho Constitucional Profundizado* RÉPLICA aplicando de forma más amplia que a los solos funcionarios de alto rango, alcanzando también a personas que, sin detentar una función pública, tienen una notoriedad amplia entre la población.

14.4. La doctrina Campillay

Desarrollo propio y exclusivo del derecho argentino (fallo “Campillay”, CSJN, 1986), que prevé tres dispositivos mediante los cuales, con un ejercicio prudente de la libertad de información, los medios pueden asegurarse la no responsabilidad por la circulación de información falaz:

1. **Cita de la fuente:** una cita concreta, clara, identificable y de buena fe, no una mera alusión vaga.
2. **Omisión de la identidad** de la persona sobre la que se informa, de modo que no haya daño a su reputación ni a su honor.
3. **Modo potencial:** la información se difunde sin asegurar su carácter inexcusable o indudable, en tono conjetural.

Con que se concrete fehacientemente uno solo de estos presupuestos, no hay responsabilidad del medio.

Cuadro 14.1: Real malicia y doctrina Campillay

Doctrina	Origen	Presupuesto central	Efecto
Real malicia	Jurisprudencia de EE.UU., adoptada por la CSJN	Falsedad de la información y conocimiento previo de esa falsedad por el medio	Habilita la responsabilidad civil frente a personas públicas
Campillay	Jurisprudencia propia de la Corte argentina	Omisión de identidad, cita de fuente o modo potencial	Exime de responsabilidad al medio que cumple alguno de estos recaudos

CAPÍTULO 14. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA.
DOCTRINA CAMPILLAY Y DOCTRINA DE LA REAL MALICIA. DERECHO DE
Derecho Constitucional Profundizado RÉPLICA
**14.5. El derecho de réplica: el caso “Ekmekdjian c/
Sofovich”**

Los apuntes de la cátedra no traían desarrollo del derecho de réplica, tema que el cronograma de la Comisión 603 ubica en una clase posterior a la fecha de este primer parcial, pero que la guía de preguntas incluye expresamente. El desarrollo que sigue se elaboró consultando el texto del fallo “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros” (CSJN, 07/07/1992, Fallos 315:1492) y comentarios doctrinarios especializados (véase la bibliografía final).

Derecho de toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su perjuicio a través de un medio de comunicación, a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta, en las condiciones que establezca la ley (art. 14, Convención Americana sobre Derechos Humanos — Pacto de San José de Costa Rica).

14.5.1. Los hechos del caso

El escritor Dalmiro Sáenz efectuó, en el programa televisivo “La Noche del Sábado”, conducido por Gerardo Sofovich, expresiones que Miguel Ángel Ekmekdjian —abogado y docente de derecho constitucional— consideró gravemente ofensivas hacia Jesucristo y la Virgen María, y por las que se sintió lesionado en sus sentimientos religiosos. Ekmekdjian remitió una carta documento al conductor del programa solicitando que la leyera al aire, en ejercicio del derecho de réplica; ante la negativa de Sofovich, inició una acción de amparo fundada en el artículo 33 de la Constitución Nacional y en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica. Tanto la primera instancia como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazaron el amparo, sosteniendo que el derecho de réplica, aunque reconocido por el Pacto, requería una ley del Congreso que lo reglamentara para ser operativo —siguiendo el criterio que la propia Corte había sostenido pocos años antes, en “Ekmekdjian c/ Neustadt” (1988)—.

14.5.2. La decisión de la Corte Suprema

La Corte Suprema, revirtiendo su propio precedente anterior, hizo lugar al amparo y sentó dos reglas centrales:

1. **El derecho de réplica es operativo, sin necesidad de ley reglamentaria.** La Corte reinterpretó la frase del artículo 14.1 del Pacto de San José —“en las condiciones que establezca la ley”— no como una condición suspensiva que subordinara la existencia misma del derecho a que el Congreso dictara una ley, sino como una simple referencia a cuestiones de implementación práctica (el espacio o el lapso en

CAPÍTULO 14. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA. DOCTRINA CAMPILLAY Y DOCTRINA DE LA REAL MALICIA. DERECHO DE *Derecho Constitucional Profundizado* RÉPLICA (que debe ejercerse la respuesta). El derecho de réplica, sostuvo la Corte, “existe e integra nuestro ordenamiento jurídico sin necesidad de que se dicte ninguna ley”.

2. **Primacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno.** Con apoyo en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados —según el cual un Estado no puede invocar su propio derecho interno para justificar el incumplimiento de un tratado—, la Corte afirmó la prioridad de las normas de un tratado internacional ratificado por el país por sobre la legislación interna. Este criterio, sentado dos años antes de la reforma constitucional, anticipó el régimen que consagraría el artículo 75, inciso 22 CN a partir de 1994.

Requisitos para el ejercicio del derecho de réplica según “Ekmekdjian”. Para que proceda, quien reclama debe estar directamente aludido por la información difundida —no basta con sentirse dolido en términos generales por una expresión que no lo menciona a él en particular—, y el espacio que ocupe la respuesta debe ser el adecuado a su finalidad, sin que necesariamente deba coincidir en extensión y ubicación con la publicación original.

14.6. Relación entre las cuatro doctrinas de este capítulo

Cuadro 14.2: Cuatro mecanismos frente a la libertad de expresión y sus límites

Mecanismo	Momento en que opera	Función
Prohibición de censura previa	Antes de la difusión	Impide todo control estatal preventivo sobre el contenido a publicar
Doctrina Campillay	Al momento de informar	Permite al medio eximirse de responsabilidad ulterior si cumple ciertos recaudos formales
Real malicia	Después de difundida la información, frente a una demanda de una persona pública	Exige probar el conocimiento previo de la falsedad para que el medio responda
Derecho de réplica	Después de difundida la información, a instancia del afectado	Permite a la persona aludida responder por el mismo medio, sin necesidad de acreditar dolo ni falsedad del medio

Una distinción clave: el derecho de réplica no exige demostrar que el medio actuó con real malicia ni que incumplió los recaudos de Campillay. Es un remedio más simple y más rápido: basta con estar aludido por una información que se considera inexacta o agravante para tener derecho a responder por el mismo medio, sin necesidad de un juicio de responsabilidad civil previo. Real malicia y Campillay, en cambio, operan como estándares para determinar si el medio debe indemnizar el daño causado.

La libertad de expresión tiene una doble dimensión —individual y social— que la convierte en un pilar del sistema democrático, razón por la cual el sistema interamericano prohíbe de manera casi absoluta la censura previa (art. 14 CN y art. 13, Pacto de San José): ningún contenido puede impedirse antes de su difusión, salvo la protección de menores. El control estatal, en cambio, es siempre reparador: opera después de la difusión, a través de dos estándares que matizan la responsabilidad de los medios frente a la persona afectada —la real malicia, de origen norteamericano, que exige probar que el medio conocía la falsedad de lo difundido y aun así lo publicó; y la doctrina Campillay, de creación exclusivamente argentina, que exime de responsabilidad al medio que citó la fuente, omitió la identidad del aludido o informó en modo potencial—. A esos dos estándares se suma el derecho de réplica, reconocido como operativo —sin necesidad de ley reglamentaria— en “Ekmekdjian c/ Sofovich” (CSJN, 1992): la persona directamente aludida por una información inexacta o agravante puede exigir responder por el mismo medio, con apoyo directo en el artículo 14 del Pacto de San José de Costa Rica, sin necesidad de acreditar previamente dolo, negligencia grave o incumplimiento de recaudo formal alguno por parte del medio.

14.7. Cuadro Cornell: libertad de expresión

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es la doble dimensión de la libertad de expresión?	La dimensión individual (expresar y difundir el propio pensamiento) y la dimensión social o colectiva (recibir información, como condición de la democracia).
¿Qué es la censura previa y por qué está prohibida?	Todo control estatal anterior a la difusión de una expresión; está prohibida (art. 14 CN, art. 13 Pacto de San José) porque impide que la expresión llegue siquiera a existir en el debate público.
¿Qué es la doctrina de la real malicia?	La regla de <i>New York Times v. Sullivan</i> : el medio solo responde ante una persona pública si esta prueba que el medio conocía de antemano la falsedad de la información y aun así la difundió.
¿Cuáles son los tres presupuestos de la doctrina Campillay?	Cita de la fuente, omisión de la identidad del sujeto, o uso del modo potencial; basta con uno para eximir de responsabilidad al medio.

¿Qué resolvió “Ekmekdjian c/ Sofovich”?

Que el derecho de réplica del artículo 14 del Pacto de San José es operativo sin necesidad de ley reglamentaria, y que los tratados internacionales priman sobre el derecho interno (art. 27, Convención de Viena).

¿En qué se diferencia el derecho de réplica de la real malicia y de Campillay?

No exige probar dolo, negligencia ni incumplimiento de recaudos formales: basta con estar directamente aludido por una información inexacta o agravante.

Resumen: la libertad de expresión, en su doble dimensión, es incompatible con cualquier forma de censura previa, y se concilia con la responsabilidad de los medios mediante dos estándares complementarios y posteriores a la difusión: la real malicia, que exige probar el conocimiento previo de la falsedad cuando se trata de personas públicas, y Campillay, que exige de responsabilidad con el cumplimiento de recaudos formales. El derecho de réplica, reconocido como operativo en “Ekmekdjian c/ Sofovich” (1992), ofrece a la persona aludida una vía más directa e inmediata de respuesta, con apoyo en el Pacto de San José de Costa Rica y sin necesidad de acreditar previamente la responsabilidad civil del medio.

Síntesis final: cómo se conectan las catorce preguntas

La guía de examen no es una lista de temas sueltos, sino un recorrido con una lógica interna. Puede reconstruirse así:

1. Todo empieza con la **interpretación** (Capítulo 1): antes de aplicar la Constitución hay que decidir cómo leerla, y esa elección metodológica —textualismo o no textualismo— condiciona cualquier respuesta posterior. La distinción entre *holding* y *obiter dictum* es la herramienta que permite leer correctamente cualquier precedente citado en el resto de la guía.
2. Una vez que se sabe cómo interpretar, surge la pregunta de **quién** tiene la última palabra sobre esa interpretación cuando una norma parece contradecir la Constitución: el **control de constitucionalidad** (Capítulo 2), ejercido en la Argentina de manera **difusa** (Capítulo 3) y con el problema de fondo de que quien lo ejerce —el Poder Judicial— no tiene mandato electoral directo, lo que plantea la objeción **contramayoritaria** (Capítulo 4).
3. Ese control necesita un cauce procesal para llegar hasta la Corte Suprema: el **recurso extraordinario federal**, cuyo núcleo es la **cuestión federal** (Capítulo 5), complementado por la vía paralela de la **arbitrariedad de sentencia** (Capítulo 6) y por la facultad de declarar la inconstitucionalidad **de oficio** (Capítulo 7). Sus **requisitos** formales, comunes y propios (Capítulo 8) determinan cuándo procede; si se deniega, queda la **queja** (Capítulo 9); mientras tanto, puede necesitarse una **medida cautelar** (Capítulo 10); y, en supuestos excepcionalísimos de gravedad institucional, puede saltarse directamente a la Corte mediante el **per saltum** (Capítulo 11).
4. Finalmente, todo ese aparato de control se pone a prueba frente a los **derechos individuales** más sensibles: el **principio de reserva** y la **objeción de conciencia** (Capítulo 12), la **libertad religiosa** (Capítulo 13) y la **libertad de expresión** (Capítulo 14), donde vuelven a aparecer, aplicadas a casos concretos, las categorías sospechosas (eco de la teoría contramayoritaria) y la exigencia de que cualquier restricción estatal sea posterior y nunca preventiva (eco de la prohibición de censura previa).

Estrategia de estudio. Al repasar cada pregunta, conviene preguntarse siempre: (i) ¿qué corriente de interpretación está en juego, si la hay?; (ii) ¿qué tipo de cuestión federal se plantea?; (iii) ¿qué fallo o doctrina la ilustra, y cuál es su *holding*?; y (iv) ¿cómo se conecta con las demás preguntas de la guía? Responder mecánicamente cada punto por separado, sin advertir estas conexiones, es el error más frecuente en un examen de esta materia.

Bibliografía y fuentes

Material proporcionado por la cátedra

- Apuntes integrados de Derecho Constitucional Profundizado (2026), elaborados por Isaac Edgar Camacho Ocampo a partir de la transcripción de las clases y los apuntes originales de la materia.
- Cronograma de clases de Derecho Constitucional Profundizado, Comisión 603, 2.º cuatrimestre de 2026 (docentes: Dr. Andrés Uslenghi y Dr. Darío M. Luna).
- Guía de preguntas del primer parcial, a rendirse el 28 de septiembre de 2026.
- Sola, Juan Vicente, *Manual de Derecho Constitucional*, La Ley, 2010; *Tratado de Derecho Constitucional*, Lexis Nexis, 2012.
- Ely, John Hart, *Democracia y desconfianza*, Universidad de los Andes, Bogotá, 1997.

Fuentes externas consultadas para completar puntos no desarrollados en los apuntes

- Sobre *holding* y *obiter dictum*: Domenech, Ernesto E., “Dicho sea de paso: obiter dicta”, Universidad Nacional de La Plata (SEDICI); “Distinción entre *holding* y *obiter dicta*”, material docente, Universidad Nacional de Mar del Plata; artículo sobre el precedente “Einaudi” de la CSJN (CONICET).
- Sobre el Poder Judicial contramayoritario y la teoría de Ely: Bickel, Alexander M., *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics*, Yale University Press, 1962; Carnota, Walter F., “Minorías ni tan ‘discretas’ ni tan ‘insulares’: la Suprema Corte de los Estados Unidos frente a la discriminación hoy”, *Revista Derecho de las Minorías*, vol. 3, 2020; Sola, Juan Vicente, “Sobre las minorías discretas e insulares y *Carolene Products*”, Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas; “¿La Justicia debe ser independiente de la mayoría?”, Chequeado.
- Sobre objeción de conciencia: fallo “Portillo, Alfredo s/ infracción art. 44 Ley 17.531” (CSJN, 18/04/1989, Fallos 312:496); fallo “Bahamondez, Marcelo s/ medida cautelar” (CSJN, 06/04/1993, Fallos 316:479); Godachevich, Mariano Gabriel, “Una aproximación a la objeción de conciencia al servicio militar. Aspectos constitucionales (nota

CAPÍTULO 14. LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA.

DOCTRINA CAMPILLAY Y DOCTRINA DE LA REAL MALICIA. DERECHO DE

Derecho Constitucional Profundizado RÉPLICA
~~al fallo “Portillo, Alfredo”, CSJN, 18/4/89)”, Facultad de Derecho, UBA, Legarre,~~
Santiago, “Objeción de conciencia sin precedentes”, Universidad Católica Argentina.

- Sobre el derecho de réplica: fallo “Ekmekdjian, Miguel A. c/ Sofovich, Gerardo y otros” (CSJN, 07/07/1992, Fallos 315:1492).

El cronograma de la cátedra menciona, junto a “Portillo” y “Bahamondez”, un tercer fallo bajo el apellido “Sisto” en materia de objeción de conciencia. No fue posible identificar y verificar con las fuentes disponibles la carátula exacta, el tribunal y el contenido de ese precedente. Se recomienda verificarlo directamente con la cátedra antes de utilizarlo como referencia de examen.